

[서식] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100-5 대 2400.2㎡ 이 상
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 위탁자 지위이전
등기의 목적	위탁자 지위이전으로 인한 변경
변경 할 사항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1112호 신탁원부의 위탁자 “서울시 서초구 서초로00길 122-3 김철수”를, “서울시 서초구 방배로00길 552-3 이창동”으로 변경
수탁자 겸 등기신청인 서울부동산신탁 주식회사 서울 서초구 서초로223길 66 대표이사 김갑수	법무사 정 인 구 서울 서초구 서초로223길 66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인
감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제4장 신탁재산에 대한 집행과 등기

제1절 총 설

1. 서 설

가. 개 설

신탁법 제22조는 “① 신탁재산에 대하여는 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분(이하 “강제집행등”이라 한다) 또는 국세 등 채납처분을 할 수 없다. 다만, 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우에는 그러하지 아니하다. ②위탁자, 수익자나 수탁자는 제1항을 위반한 강제집행 등에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 민사집행법 제48조를 준용한다. ③위탁자, 수익자나 수탁자는 제1항을 위반한 국세 등 채납처분에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 국세 등 채납처분에 대한 불복절차를 준용한다.”고 규정하고 있다.

구 신탁법은 “강제집행 또는 경매”라고 규정하고 있어서 신탁재산에 대하여 가압류·가처분 등의 보전처분이 금지되는지는 해석상으로 인정되었으나 개정 신탁법에서는 보전처분이 포함됨을 명시하였고, 구 법에서는 위탁자의 상속인도 위법한 강제집행 등에 대한 이의신청권자로 규정되어 있었으나 개정 신탁법에서는 위탁자의 상속인을 삭제하였다.

신탁재산은 수탁자의 파산재단, 회생절차의 관리인이 관리 및 처분 권한을 갖고 있는 채무자의 재산이나 개인회생재단을 구성하지 아니한다(신탁법 제24조). 신탁재산에 속하는 채권과 신탁재산에 속하지 않는 채무는 상계(相計)하지 못한다. 다만, 양 채권·채무가 동일한 재산에 속하지 않음에 대하여 제3자가 선의이며 과실이 없을 때에는 그렇지 아니한다(신탁법 제25조제1항).

신탁재산에 속하는 채무에 대한 책임이 신탁재산만으로 한정되는 경우에는

신탁재산에 속하지 않는 채권과 신탁재산에 속하는 채무는 상계하지 못한다. 다만, 양 채권·채무가 동일한 재산에 속하지 않음에 대하여 제3자가 선의이며 과실이 없을 때에는 그렇지 아니한다(신탁법 제25조제2항).

또한 혼동(混同)으로 인하여 권리가 소멸하지 아니한다(신탁법 제26조).

나. 강제집행에 대한 이의

위탁자, 수익자나 수탁자는 위의 규정을 위반한 강제집행등에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 민사집행법 제48조(제3자이의의 소)를 준용한다(신탁법 제22조제2항). “제3자이의의 소”란 제3자가 강제집행의 목적물에 대하여 소유권을 주장하거나 목적물의 양도나 인도를 저지하는 권리를 주장하기 위하여 채권자를 상대로 제기하는 강제집행에 대한 이의의 소를 말한다(민사집행법 제48조). 제3자이의의 소는 강제집행 개시 후 그 종료 전에만 이를 제기할 수 있다. 이 소는 원칙적으로 집행법원의 관할에 속한다.

신탁재산에 대하여는 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분(이하 “강제집행등”이라 한다) 또는 국세 등 체납처분이 있는 경우에는 위탁자, 수익자나 수탁자가 위반한 국세 등 체납처분에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 국세 등 체납처분에 대한 불복절차를 준용한다(신탁법 제22조제3항).

2. 강제집행 등을 할 수 있는 경우

가. 개 설

신탁법상의 신탁재산은 수탁자의 고유재산으로부터 구별되어 관리될 뿐만 아니라 위탁자의 재산권으로부터도 분리되어 독립성을 갖게 되는 것이고(대법원 1987.5.12. 선고 86다545, 86다카2876 판결), 신탁법 제22조 제1항 단서의 예외의 경우에만 강제집행이 허용될 뿐인 것이다(대법원 1987.5.12. 선고 86다545, 86다카2876 판결).

나. 신탁 전의 원인으로 발생한 권리

(1) 의 의

신탁법 제22조 제1항 단서의 「신탁전의 원인으로 발생한 권리」라 함은 신탁전에 신탁부동산에 대하여 저당권, 전세권, 임차권 등의 각 설정등기, 담보가 등기 또는 가압류, 가처분등기 등이 경료된 경우와 같이 신탁재산 그 자체를 목적으로 하는 채권이 발생한 경우를 말하는 것이고, 신탁전에 위탁자에 관하여 생긴 모든 채권이 이에 포함되는 것은 아니다. 즉, 위탁자가 저당권 등이 설정된 부동산을 신탁한 경우와 같이 신탁 전에 이미 신탁재산에 대하여 경매를 실행할 수 있는 권리가 있었던 경우를 의미한다.⁸⁸⁾

“신탁 전”의 의미에 대하여 ‘신탁행위 전’으로 한정할 것이 아니라, ‘개별적인 신탁재산에 관하여 신탁의 법률관계가 성립하기 전’으로 넓게 해석하여야 한다고 보아, 수탁자가 신탁재산을 관리하던 중 저당권이 설정된 부동산을 신탁재산으로 취득한 경우에도 저당권의 실행을 인정하여야 한다고 해석한다.⁸⁹⁾

위탁자가 신탁제도를 집행면탈의 목적으로 악용하는 것을 방지하기 위하여, 위탁자의 채권자가 신탁관계가 성립되기 전에 신탁재산에 대하여 취득한 권리에 기하여는 강제집행 등을 할 수 있다. 신탁재산인 부동산에 대하여 신탁설정 전에 저당권이 설정되거나 대항력이 있는 임차권이 설정되는 경우 등이 대표적인 예이다.

판례는 계약금반환 채권에 기하여 위 부동산의 가압류를 신청한데 대하여 “신탁법상의 신탁재산은 수탁자에게 귀속되는 일방 그 고유재산과도 구별되어 독립성을 갖게 되는 것이어서 신탁등기 후에는 신탁재산에 가압류(압류)할 수 없다(대법원 1987.5.12. 선고 86다545,86다카2876 판결).”라고 판시하였다.

또한 판례는 위탁자가 상속받은 재산을 신탁한 경우, 그 재산상속에 따라 위탁자에게 부과된 상속세 채권을 가지고 압류한 사건에서 “신탁대상 재산이 신탁

88) 신탁법상의 신탁이 이루어진 후에 위탁자에 대한 부가가치세 채권에 기하여 신탁재산을 압류한 이 사건 압류처분은 당연무효라 할 것이다(대전지방법원 2009. 9. 30. 선고 2009구합1077 판결)

89) 오영준, 신탁재산의 독립성 867쪽. 김성필, 신탁재산의 법률관계 민사법학 제17호 한국민사법학회 206쪽.

자에게 상속됨으로써 부과된 국세라 하더라도 신탁법상의 신탁이 이루어지기 전에 압류를 하지 아니한 이상 신탁법상의 신탁이 이루어진 후에는 위탁자에 대한 조세채권에 기하여 신탁재산을 압류할 수 없다(대법원 1996.10.15. 선고 96다17424 판결).”고 판시하였다.

따라서 위탁자에 대하여 「신탁전의 원인으로 발생한 권리」 외의 채권을 가지고 있는 채권자일 경우에는 신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 위탁자가 수익자인 경우(자익신탁)에 한하여 그 수익권을 가압류하거나 신탁법 제8조에 의한 사해행위취소권을 행사하는 방법(578면 참조)을 이용하여 권리구제를 받을 수 있을 뿐이다.

(2) 권리의 범위

적용대상이 되는 권리는 ‘신탁재산 그 자체를 목적으로 하여 발생한 채권’을 의미하는 것으로 신탁 전에 위탁자에 관하여 생긴 모든 채권이 포함되는 것은 아니므로(대법원 1987.5.12. 선고 86다545, 86다카2876 판결), 위탁자의 채권자가 일반채권을 갖고 있는 경우에는 해당하지 아니하다.⁹⁰⁾ 다만 일반채권자가 신탁 전에 신탁재산에 대하여 압류·가압류를 한 경우에는 처분금지효에 의하여 압류·가압류의 범위내에서는 신탁에 의한 권리이전을 대항할 수 없으므로, 해당채권이 신탁재산 자체를 목적으로 하는 채권이 아니더라도 본 압류로의 이행 또는 강제집행이 가능하다고 보아야 한다.⁹¹⁾ 영업의 신탁과 같이 신탁을 설정할 때 소극재산도 함께 신탁재산으로 인수한 경우 위탁자의 채권자는 그 채무에 대한 권리에 기하여 강제집행 등을 할 수 있다.⁹²⁾

다. 신탁사무처리상 발생한 권리

(1) 개 설

수탁자가 신탁사무를 처리하는 과정에서 제3자가 취득한 신탁채권은 신탁재

90) 오영준, 신탁재산의 독립성 867쪽.

91) 오영준, 신탁재산의 독립성 867~868쪽.

92) 이증기, 신탁법 177쪽.

산에 대한 채권이므로 강제집행 등을 막는 것은 부당하므로 당연히 신탁재산에 대하여 강제집행 등의 행사가 가능하다(신탁법 제22조제1항 단서).

(2) 권리의 범위

“신탁사무의 처리상 발생한 권리”라 함은 수탁자의 사무처리행위에 의하여 생긴 권리(신탁재산의 수리비 채권)와 신탁재산 자체에서 유래하는 권리(신탁재산에 관한 조세, 공과금, 신탁사무처리로 매각된 신탁재산의 숨은 하자로 인한 담보책임, 민법 제580조), 신탁재산에 속한 공작물의 하자에 기한 소유자의 책임(민법 제758조), 신탁재산과 타인의 재산과의 침부에 의하여 발생한 물건이 수탁자에게 귀속한 경우에 있어서의 부당이득반환의무(민법 제261조)에 대응하는 상대방의 권리, 신탁목적수행을 위해서 적법하게 차입한 상대방의 채권 등 도 이에 포함된다.

한편 판례는 “신탁사무의 처리상 발생한 채권”을 가지고 있는 채권자는 수탁자의 일반채권자와는 달리 신탁재산에 대하여 강제집행을 할 수 있는데, 여기서 말하는 ‘신탁사무의 처리상 발생한 채권’에는 신탁재산의 관리 또는 처분 등 신탁업무를 수행하는 수탁자의 통상적인 사업활동상의 행위로 인하여 제3자에게 손해가 발생한 경우 피해자인 제3자가 가지는 불법행위에 기한 손해배상채권도 포함되는 것으로 봄이 상당하다. 왜냐하면, 신탁자 또는 수탁자의 고유재산으로부터 신탁재산의 독립성을 보장하려는 것이 신탁법의 고유한 목적임을 감안한다 하더라도, 오늘날 수탁자의 사무가 전통적인 영역인 단순한 재산 관리의 수준을 넘어서서 활발한 대외적인 활동을 수반하기에 이른 만큼 그에 상응하여 피해자에 대한 보호방안의 필요성을 외면하기 어렵고, 다른 한편으로 대리인이나 고용인이 그 자신의 일반적인 권한 내에서 행동한 경우 본인이나 사용자에게 책임을 귀속시킬 수 있듯이 그 자신의 일반적인 권한 내에서 행동하는 수탁자는 비록 신탁자 개인에게 책임을 귀속시킬 수는 없다고 하더라도 신탁재산에 대하여는 책임을 귀속시킬 수 있다고 보는 것이 공평에 부합한다고 할 것이기 때문이다. 그리고 이러한 이유에서 피해자인 제3자로 하여금 신탁재산에 대한 강제집행을 할 수 있도록 허용하는 것이므로, 신탁업무를 수행하는 수탁자의 통상적

인 사업활동상의 행위로 인하여 제3자에게 손해가 발생한 경우인 이상, 신탁재산에 속하는 공작물의 숨은 하자에서 생기는 불법행위에 기한 손해배상채권이 나 신탁사무의 처리로서 매각한 신탁재산의 숨은 하자에 대한 담보책임과 같이 신탁재산 자체에서 연유하는 권리와 대비하여 원심이 지적하는 바와 같은 이른바 ‘신탁재산에 기인하지 않은 불법행위로 인한 손해배상채권’ 중에서 그 불법행위로 증가된 신탁재산의 가치와 채권자의 손실 사이에 어떠한 대가적인 관련이 없는 경우라 할지라도 ‘신탁사무의 처리상 발생한 채권’에 해당하지 않는다고 보아 신탁재산에 대하여 강제집행이 허용되지 않는다고 할 수는 없다(대법원 2007.6.1. 선고 2005다5843 판결).”고 판시한 것이 있다.

여기서 “수탁자가 신탁사무를 처리하는 과정에서 채무를 부담하는 경우” 그 책임의 범위가 신탁재산의 한도 내로 제한되는지에 관하여 판례는 “수탁자의 이행책임이 신탁재산의 한도 내로 제한되는 것은 신탁행위로 인하여 수익자에 대하여 부담하는 채무에 한정되는 것이므로(신탁법 제38조), 수탁자가 수익자 이외의 제3자 중 신탁재산에 대하여 강제집행을 할 수 있는 채권자에 대하여 부담하는 채무에 관한 이행책임은 신탁재산의 한도 내로 제한되는 것이 아니라 수탁자의 고유재산에 대하여도 미치는 것으로 보아야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004다31883,31890 판결).”고 판시하였다.

(3) 채무자로 할 수 있는 자

“신탁사무의 처리상 발생한 권리”에는 수탁자를 채무자로 하는 것만 포함되며, 위탁자를 채무자로 하는 것은 포함되지 않는다(대법원 2013.1.24. 선고 2010두27998 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2010두4612 판결 등).

※ 위 판례 원문

채납처분으로서 압류의 요건을 규정한 구 지방세법(2010. 3. 31. 법률 제 10221호로 전부 개정되기 전의 것) 제28조의 규정을 보면 어느 경우이나 압류의 대상을 납세의무자 또는 특별징수의무자의 재산에 국한하고 있으므로, 납세의무자 또는 특별징수의무자가 아닌 제3자의 재산을 대상으로 한 압류처분은 그 처분의 내용이 법률상 실현될 수 없는 것이어서 당연무효이

다.

원심은 그 채용 증거를 종합하여, 주식회사 ○○○(이하 ‘소외 회사’라 한다)는 2007. 7. 5. 및 2007. 8. 8. 원고와 이 사건 각 부동산 등에 관하여 부동산담보신탁계약을 체결하고 그 무렵 원고에게 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳐 준 사실, 소외 회사가 취득세, 등록세 및 재산세를 체납하자 피고는 2009. 9. 22. 소외 회사를 체납자로 하여 신탁재산인 이 사건 각 부동산을 압류하는 이 사건 처분을 한 사실 등을 인정한 다음, 신탁법 제21조 제1항 단서(개정 신탁법 제22조 제1항 단서)에서 말하는 ‘신탁사무의 처리상 발생한 권리’는 수탁자가 신탁사무와 관련한 행위를 함으로써 수탁자에 대하여 발생한 권리를 의미한다고 전제하고, 이 사건 처분에 관계된 취득세, 등록세 및 재산세 채권은 위탁자인 소외 회사에 대한 채권으로서 여기에 해당한다고 할 수 없다는 이유로, 소외 회사에 대한 취득세, 등록세 및 재산세 채권에 기하여 원고 소유의 신탁재산을 압류한 이 사건 처분은 무효라고 판단하였다.

앞서 본 규정과 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 신탁법 제21조 제1항 단서(개정 신탁법 제22조 제1항 단서)에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

제2절 신탁전의 원인에 의한 강제집행

1. 서 설

가. 개 설

신탁법 제22조는 “신탁재산에 대하여는 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분(이하 “강제집행 등”이라 한다) 또는 국세 등 채납처분을 할 수 없다. 다만, 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고, 신탁등기사무처리에 관한 예규(제1799호)는 “등기관은 수탁자를 등기의무자로 하는 처분제한의 등기, 강제경매등기, 임의경매등기 등의 촉탁은 이를 수리하고, 위탁자를 등기의무자로 하는 위 등기의 촉탁은 이를 수리하여서는 아니된다. 다만, 신탁 전에 설정된 담보물권에 기한 임의경매등기 또는 신탁전의 가압류등기에 기한 강제경매등기의 촉탁에 있어서는 위탁자를 등기의무자로 한 경우에도 이를 수리하여야 한다.”라고 하여 위 범조항을 뒷받침하였다.

따라서 “저당권 등이 설정된 부동산을 신탁한 경우”와 “신탁사무의 처리 중에 신탁부동산에 저당권 등을 설정한 경우”와 같이 신탁 전에 이미 신탁재산에 대하여 경매를 실행할 수 있는 권리의 채권을 가지고 있는 채권자는 수탁자를 집행채무자로 하여 신탁재산에 대하여 담보권실행에 의한 경매를 할 수 있다.

강제집행 등이 허용되는지 여부는 신탁재산에 대한 강제집행여부를 결정하는 단계에서 집행법원이 심사하여야 할 사항이다(등기선례6-470, 2000. 7. 28. 등기 3402-526 질의회답).

나. 집행절차

(1) 개 설

수탁자를 집행채무자로 하여 담보권실행에 의한 경매(임의경매)를 신청한다. 담보권실행 등을 위한 경매라 함은 장래 자기가 입게 될 불이익의 보상으로 하는 담보 즉, 채무자의 채무불이행에서 오는 손해를 확보하기 위한 수단으로 채

권자에게 제공되어 있던 담보권을 채무자의 채무불이행시 채권자의 신청에 의하여 국가의 집행기관이 이를 경매에 부쳐 현금화하여 채권의 만족을 얻게 하는 것을 말한다.

위 신탁재산의 경우 실질적인 채무자는 위탁자이지만 경매 신청에 있어서의 집행채무자는 현재 형식상 소유권의 등기명의인인 수탁자이다.

등기선례는 “위탁자가 신탁을 원인으로 부동산의 소유권을 수탁자에게 이전하면 신탁재산은 수탁자에게 귀속되므로 수탁자 명의의 신탁부동산에 대하여 수탁자에 대한 압류조서를 첨부하고 수탁자를 등기의무자로 하여 압류등기를 촉탁한 경우에는 수리할 수 있다. 이와 달리 수탁자 명의의 신탁부동산에 대하여 위탁자를 등기의무자로 하여 압류등기를 촉탁한 경우에는 촉탁서상의 등기의무자의 표시가 등기부와 부합하지 아니하여 수리할 수 없다. 또한, 수탁자 명의의 신탁부동산에 대하여 위탁자에 대한 압류조서를 첨부하고 수탁자를 등기의무자로 하여 압류등기를 촉탁한 경우에는 촉탁서에 기재된 사항이 등기원인을 증명하는 서면과 부합하지 아니하여 수리할 수 없다(등기선례 201001-1, 2010. 1. 16. 부동산등기과-123 질의회답).”고 하였다.

(3) 사해행위취소의 확정판결로 인한 강제경매개시결정 등기촉탁

사해행위 취소의 확정판결을 받은 때라도 그 판결에 의하여 채무자 명의로 등기가 되지 않은 경우, 동 확정판결에 따라 등기관이 강제경매개시결정과 함께 직권으로 채무자 명의로 등기를 할 수 있다는 등의 법령상 명문규정이 없는 이상 채무자를 등기의무자로 한 강제경매개시결정의 등기촉탁은 수리될 수 없다(등기선례 제200705-4호, 2007. 5. 30. 부동산등기과-1796 질의회답).

2. 신청절차

가. 개 설

임의경매의 신청은 반드시 서면으로 하여야 하며(민집법 제4조, 제275조), 신청서에는 소정의 사항을 기재하여야 하고(민집법 제268조, 제80조), 소정의 서류를 첨부하여야 한다(민집법 제264조 제1항, 제2항, 제268조, 제81조).

나. 인지 등

① 신청서에는 5,000원의 인지를 붙인다(재민 91-1). 동일 채권자가 동일 채무자 또는 수인의 채무자에 대한 각별 수개의 채권에 관하여 저당권이 설정된 일개 또는 수개의 부동산에 대하여 경매의 신청을 1건으로 1통의 신청서로써 한 경우에 이는 본래 수개의 독립된 신청으로 할 것을 편의상 1건으로 신청한 것에 불과하므로 적용인지는 저당권마다 소정의 인지를 붙여야 한다(재민 69-1).

② 송 달 료 : (신청서상의 이해관계인+3)×10회분(1회분 5,500원)

③ 수수료 : 부동산 1필지당 4,000원

④ 경매예납금 : 신문공고료, 현황조사료, 매각수수료, 감정료, 유찰수수료를 납부한다(법원에 문의하면 구체적으로 알려준다).

⑤ 등록면허세 : 채권금액의 1000분의 2(지방세법 제131조 제1항 제7호)

⑥ 교육세 : 등록면허세의 100분의 20(지방세법 제260조의3 제1항 제1호)

⑦ 신청서류 : 신청서 1통 및 부동산목록 40통을 제출한다.

⑧ 신청법원 : 경매목적 부동산이 있는 곳의 지방법원(민집법 제79조 제1항, 제268조)

⑨ 기타 :

집행권원에 표시된 채권자와 채무자의 주소, 성명이 토지 또는 건물의 등기부등본에 기재된 것과 상이한 경우에 있어서는 그 연혁을 명백히 한다.

경매신청의 채권자가 법인인 때 또는 무능력자인 경우에 있어서는 그 대리 자격을 증명하는 법인등기부등초본 또는 가족관계등록증명서를 첨부한다.

경매신청표지 다음에 이해관계인일람표 그리고 부동산임의경매신청서의 순으로 철하고 첨부하여야 한다.

[서식] 부동산임의경매신청서(신탁전의 원인으로 발생한 권리에 의한)

부동산 임의경매 신청

채 권 자 (주) ○○은행
서울 강북구 수유동 123-2(우:)
대표이사 이 달 준
지 배 인 유 동 선
(소관 : ○○관리부) 전화 : 963-4564

채 무 자 유 정 영
서울시 서초구 서초동 123-5(우)
전화 : 593-2365

소유자 겸 수탁자 서울○○신탁 주식회사
서울시 서초구 서초동 123-5(우)
대표이사 신 탁 문
전화 : 553-6458

청 구 금 액
금000,000,000원정(20 . 7. 12자 대여금)
위 금원에 대한 20 . 7. 12부터 완제일까지 연 12%의 이자

경매할 부동산의 표시
별지목록 기재와 같음

신 청 취 지

채권자의 채무자에 대한 위 청구금액의 변제에 충당하기 위하여 별지 기재 부동산에 대한 경매절차를 개시하고 채권자를 위하여 이를 압류한다.

라는 재판을 구합니다.

신 청 원 인

1. 채권자는 채무자 소유인 별지목록 기재 부동산에 대하여 20 . 7. 12. 근저당권 설정계약을 체결하고 서울지방법원 용산등기소에 20 . 7. 13. 접수 제3377호 채권최고액 금00,000,000원의 채권담보로 근저당권 설정등기를 하였습니다.
2. 채권자는 차용증서에 갈음하여 20 . 7. 12. 금000,000원을 ○○조로 채무자에게 대여하면서 월 1부5리 변제기일은 20 . 2. 12. 로 약정하였습니다.
3. 그런데 채무자는 채무원금은 물론 약정이자조차 지급치 않고 있어 채권자는 근저당권 실행으로 위 청구금액에 충당하기 위하여 본건 신청을 합니다.

첨 부 서 류

- | | |
|--------------|----|
| 1. 등기부등본 | 1통 |
| 1. 근저당권설정계약서 | 1통 |
| 1. 차용증서 | 1통 |
| 1. 각서 | 1통 |

20 . 5. .

채권자 (주) ○○은행 (인)

대표이사 이 달 준

지 배 인 유 동 선

서울중앙지방법원 귀중

※ 별지목록 생략

제3절 신탁전의 원인 외로 발생한 금전채권의 권리행사

제1관 서 설

신탁전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우 외의 금전채권은 신탁재산에 대하여 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분 또는 국세 등 채납처분을 할 수 없다(신탁법 제22조).

따라서 위탁자에 대하여 「신탁 전의 원인 및 신탁사무처리 중 발생한 권리」 외의 채권을 가지고 있는 채권자일 경우에는 신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 수익권에 대한 강제집행 또는 신탁법 제8조에 의한 사해행위취소권을 행사하는 방법을 이용하여 권리구제를 받을 수 있다. 차례로 보기로 한다.

제2관 수익권에 대한 강제집행

1. 서 설

가. 의 의

“수익권”이란 수익자가 신탁재산으로부터 얻는 이익과 수탁자에 대하여 가지는 각종의 권리를 말한다(신탁법 제56조). 이러한 수익권은 재산권에 해당하므로 양도성과 상속성을 가진다. 따라서 수익권을 질권으로 설정할 수도 있고, 수익자의 채권자는 그 수익권에 대하여 강제집행을 할 수도 있다.

일반 신탁절차에서는 수익권의 주된 내용은 신탁재산의 관리 처분으로 인하여 발생하는 수익금의 교부 청구권과 신탁종료시의 위탁자 앞으로의 귀속되는 부동산 소유권이전등기청구권이나, 유언대용신탁에서는 위탁자 자신을 자기생존 중 수익자로 하고, 자신의 자녀·배우자 그 밖의 자를 사후수익자로 계약하는 경우이므로 부동산 소유권이전등기청구권은 위탁자의 수익권이 아니어서 이에

대하여는 집행할 수 없다.

수익권에 대한 강제집행은 신탁관계의 존속에 직접 영향을 주는 것이 아니라서 채권자는 수익권에 기하여 추심 내지 수익권의 환가에 의하여 채권의 만족을 얻을 수 있는 것이 원칙이므로, 수익권에 대한 강제집행으로 신탁이 종료되어도 신탁법 제22조 제1항이 금지하는 강제집행에 해당하지 아니한다.

나. 수익권에 대한 강제집행

수익권은 압류금지채권(민사집행법 제246조)으로 인정되지 않는 한 강제집행을 할 수 있으며, 신탁행위에 의하여 수탁자와 위탁자간의 수익권의 양도를 금지한 경우라도 강제집행할 수 있다. 여기서 수탁자와 위탁자간의 수익권의 양도를 금지한 특약은 일신전속권을 의미하는 것은 아니며, 또한 정당한 이유없이 채권자의 압류의 권한을 박탈할 수는 없다고 보아야 하기 때문이다.⁹³⁾ 그러나 수익자의 수익권이 확정되지 아니한 경우 수익자의 채권자는 그 수익권에 대해 강제집행을 할 수 없다.⁹⁴⁾

2. 신탁수익금 가압류

가. 개 설

신탁수익금은 채권가압류에 의하여야 하고, 가압류는 「피보전권리」에 의하여 「보전의 필요성」과 「당사자능력 및 소송능력」을 갖추어야 한다.

가압류신청에는 신청취지 바로 위에 그 피보전청구권을 표시하고 그 금액을 기재한다. 그 청구권이 금전채권이 아닌 경우에는 금전으로 환산한 금액을 기재한다(민사집행법 제279조 1항). 이와 같이 피보전채권액을 기재하도록 함은 담보액이나 해방공탁금, 가압류집행의 한도를 정하는데 필요하기 때문이다. 피보전권리는 예비적·선택적으로 기재하여도 된다.

한편 가압류절차에서도 채권자는 제3채무자에게 채권의 인낙여부 등에 관하여 진술할 것을 최고하는 규정(민사집행법 제237조)이 준용되므로 채권자는 가

93) 법률출판사 발행 유재관 신탁법실무 866쪽

94) 이중기 전거서 479쪽

압류신청과 동시에 또는 집행법원의 집행시까지 그 신청을 할 수 있다.

신청서는 가압류할 부동산이 있는 곳을 관할하는 지방법원이나 본안의 관할 법원에 제출하여야 하는데, 가압류신청 진술서를 별지로 제출해야 한다.

채권자는 가압류신청을 기각하거나 각하하는 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다(민사집행법 제281조 제2항). 채무자는 가압류결정에 대한 이의신청(민사집행법 제283조), 본안의 제소명령신청(민사집행법 제287조)을 할 수 있다.

나. 신청절차

(1) 개 설

신청의 취지는 가압류신청에 의하여 구하고자 하는 보전처분신청의 목적과 한도를 나타내는 표준이 된다. 그러므로 어떠한 보전명령을 구하는지를 명백히 기재하여야 한다.

신청의 이유는 신청취지를 구하는 근거가 되는 사유를 말한다. 따라서 피보전 권리의 존재와 보전의 필요성을 구체적이고 간결하게 기재하여야 한다.

신청서에는 보전처분의 이유가 되는 사실의 소명방법을 기재하여야 한다(민사집행법 제279조 2항). 그 소명방법이 서류일 때는 그 사본 등을 첨부하여야 한다. 소명은 「즉시 조사할 수 있는 증거」에 의하여야 하므로 변론기일에 법정에서 제출할 수 있는 것으로써 서증이나 검증물 또는 당사자 본인신문 등이 이에 해당한다. 증거조사에 오랜 시일을 요하는 소명은 적당치 아니하다. 소명은 보전의 필요성에 그치지 않고 피보전권리도 그 대상이 된다.

(2) 소명방법과 첨부서류

㉠ 소명방법이란 가압류할 필요성에 대한 자료이다. 영수증이나 차용증, 약속어음·수표, 합의각서 등이다. 가압류는 가능한 변론 없이 결정의 형식으로 재판하고 있으며, 그 재판까지 시간을 최소한으로 단축시키기 위해 노력하고 있으며, 또한 증거도 증명까지는 요구하지 아니하고 소명(증명에 비하여 한 단계 낮은 개연성, 즉 대개 그럴 것이라는 추측 정도의 심증을 얻게 하는 입증행위이다)으로 족하도록 하는 것은 긴급성에 부응하고자 하는 것이다.

㉠ 첨부서류 : 첨부서류는 위 소명방법 이외에 대리인이 접수하게 되면 제출 위임장이 필요하고, 당사자(채권자·채무자·제3채무자)가 법인일 경우에는 대표자의 대표권을 증명하기 위한 자격증명서, 즉 법인등기부등본이 필요하다. 그리고 기타 부동산등기부등본이 필요할 경우에 첨부하면 된다. 소명방법에 필요한 서류들 중 재발급이 되지 않는 서류들(영수증, 차용증, 계약서 등)은 사본을 제출하지만, 재발급이 가능한 서류들(법인등기부등본, 부동산등기부등본, 주민등록표등본 등)은 그 자체를 제출해야 한다.

목록은 등기 등의 촉탁이 필요한 경우에는 그 수만큼 목록부분을 제출한다.

『예』 채권가압류 - 채무자 1인일 때 4부, 채무자 1명 추가당 1부씩 추가,

(3) 등록세 · 교육세

가압류할 부동산이 있는 시·군·구청에서 등록세과세표준 및 세액신고서를 작성하여 신고하고(부동산 목록 1통을 제출해야 한다), 고지서를 발급 받아 가까운 은행에 납부하면 된다. 직접 부동산이 있는 시·군·구청에 가지 않더라도 <http://www.wetax.go.kr>에서 발급받아 납부할 수 있다.

등록세는 가압류 할 금액의 2/1,000, 교육세는 등록세액의 20/100이다. 등록세액이 6,000원미만인 경우에는 6,000원(지방세법 제28조제1항)

채권자가 채무자의 여러 부동산을 가압류할 경우 등록세·교육세는 지방세 납부관할 소재지 한 곳을 선택하여 납부하면 된다.

(4) 신청비용

㉡ 인지대 : 10,000원, 인지는 법원구내 우체국에서 구입하여 신청서 표지에 붙인다.

㉢ 송달료 : 당사자수×5,500원×3회분. 납부는 법원구내 은행에 송달료예납 납부서를 작성하여 납부한다. 인지액과 송달료 납부는 신한은행 인터넷뱅킹으로도 납부할 수 있다. 인터넷뱅킹으로 납부할 경우 납부서를 출력하여 법원제출용은 가압류신청서 표지 뒷면에 붙여 제출하면 된다.

㉣ 촉탁수수료 : 법원은 결정과 동시에 관할등기소에 등기·등록을 촉탁하여야

함으로 촉탁수수료를 납부하여야 한다.

토지와 건물 중 하나만 가압류할 때는 4,000원, 토지와 건물 모두 가압류할 때는 8,000원, 아파트·빌라·연립의 경우는 토지와 건물을 하나로 보아 4,000원이다(등기예규 제1861호).

등기수입증지 폐지에 따라 대한민국법원 인터넷등기소를 이용하여 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 선불형지급수단)으로 납부하고 출력한 영수필확인서를 첨부하거나, 법원행정처장이 지정하는 수납금융기관 또는 무인발급기에 현금으로 납부한 후 발급받은 영수필확인서를 첨부하여야 한다(등기예규 제1733호).

다. 공탁금

채권가압류의 경우 신청서만 보여주고 기명날인 한 다음 비용(청구금액 $\times$ $2/5 \times 0.151\%$)을 내면 공탁보증보험증권을 발급해 준다. 주의할 점은 보증보험료를 산출하여 15,000원 이하로 나오면 보증보험료는 15,000원이다(즉, 최저보험료는 15,000원이다).

이때 도장을 꼭 지참해야 한다. 대리인이 공탁보증보험증권을 발급 받으려면 채권자의 인감도장이 날인된 위임장과 인감증명서 1통이 필요하다.

채권가압류에서는 담보제공액은 청구금액의 5분의2로 정하며 현금공탁 또는 보증보험증권으로 한다.

가압류신청서를 제출하고 4~5일 후에 법원의 담보제공명령서를 받은 다음 현금공탁서나 공탁보증보험증권을 발급 받아 가압류 신청서를 제출한 법원 민사신청과 가처분 담당자에게 제출하면 된다.

공탁보증보험증권 발급은 법원 앞에서 공탁 또는 보증보험이라는 간판을 내 걸고 영업을 하고 있으므로 찾기 쉽다. 담보명령서를 보여주고 기명날인 한 다음 비용을 내면 공탁보증보험증권을 발급해 준다. 이때 도장을 꼭 지참해야 한다. 대리인이 공탁보증보험을 발급 받으려면 채권자의 인감도장이 날인된 위임장과 인감증명서 1통이 필요하다.

라. 집행절차

집행기관은 가압류 발령법원이고(민사집행법 제296조 2항) 가압류 발령과 동시에 가압류 재판정본을 제3채무자에게 정본을 송달함으로써 한다. 따라서 가압류의 효력은 제3채무자에게 가압류 재판정본이 송달됨으로써 발생한다(민사집행법 제227조 3항). 제3채무자가 그 송달을 받고서도 채권을 채무자에게 지급하였다면 제3채무자는 채권자에게 대항할 수 없다(대법원 1989. 11. 24. 88다카25038 판결). 이 경우 제3채무자는 민법 제487조의 규정에 의하여 공탁을 함으로써 책임을 면할 수 있다는 판례가 있다(대법원 1994. 12. 13. 전원합의체 판결 93다951 판결).

가압류를 당한 채무자는 법률적 활동에 대하여는 제한받지 아니한다. 그러므로 피가압류채권이 시효로 소멸할 염려가 있는 때에는 시효중단을 위하여 소를 제기할 수도 있고(민법 제168조) 또는 제3채무자를 상대로 집행보전을 위하여 인정된 범위 외에서의 어떠한 법률적 활동에 대하여도 제한받지 아니한다(대법원 1991. 11. 12. 91다29736 판결).

[서식] 채권가압류신청서(신탁 수익금에 대한)

채권가압류신청

채 권 자 변 근 수

서울 종로구 종로 3가 123(우:)

전화·휴대폰번호 :

팩스번호, 전자우편(e-mail)주소 :

채 무 자 박 창 석

서울 서초구 서초동 321(우:)

전화·휴대폰번호 :

제3채무자 서울○○신탁 주식회사

서울시 서초구 서초동 123-4

전화 :

청구채권의 표시

금 10,000,000원 20○○. 5. 20. 자 약속어음금

가압류할 채권의 표시

별지 기재와 같음

신 청 취 지

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 가압류한다.
 2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니된다.
 3. 채무자는 위의 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니된다.
- 라는 재판을 구함

신 청 이 유

1. 제3채무자인 서울○○ 신탁 주식회사는 채무자인 위탁자와 20○○. ○. ○ 신탁계약을 체결하고 같은날 위탁자는 제3채무자에게 소유권이 전 및 신탁등기를 경료하였습니다. 제3채무자는 신탁설정 후 신탁재산을 관리 처분해 오고 있으며, 신탁수익금으로 채무자에게 매월 금000원을 현금으로 지급하고 있습니다.
2. 채무자는 20○○. 5. 20. 다음의 약속어음 1매를 발행하여 채권자에게 교부하였습니다.
 액 면 금 10,000,000원정
 어음번호 1234
 발 행 일 20○○. 5. 20.
 발행지 및 지급지 서울시
 지 급 일 20○○. 8. 20.
 지급장소 서울은행 서초동지점
3. 채권자는 위 어음을 지급기일에 지급장소에 임하여 지급제시를 하였던 바, 지급거절되었습니다.
4. 따라서 채권자는 현재 채무자를 상대로 약속어음금 청구의 소를 준비중에 있습니다.
5. 그러나 채무자는 채권자에 대한 위 약속어음금 채무 이외에도 다른 사람에게 많은 채무를 부담하고 있는 데, 채무자는 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재의 채권 외에는 달리 재산이 없으므로 채권자가 후일 본안소송에서 승소판결을 얻더라도 집행을 할 수 없게 될 우려가 있으므로 승소 후의 강제집행을 보전하기 위하여 미리 이 신청을 하기에 이르렀습니다.

6. 담보제공은 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법에 의할 수 있도록 허가하여 주시기 바랍니다.

소명 방법

1. 약속어음사본 1통

첨부서류

1. 소명서류 각 1통
1. 주민등록표등본 1통
1. 신탁원부 1통
1. 부동산등기부등본 1통
1. 가압류신청진술서 1통
1. 송달료납부서 1통

20〇〇. 9. .

위 채권자 변 근 수 (인)

서울중앙지방법원 귀중

※ 진술서를 첨부 제출한다.

[별지]

가압류할 채권의 표시

금 10,000,000원정

채무자가 제3채무자와 20〇〇. 〇. 〇. 서울시 〇〇구 〇〇로 00길0 대350㎡의 부동산을 신탁설정으로 인하여 제3채무자가 신탁재산을 관리·처분하고 있는바, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 신탁 수익금 청구채권 중 위 청구금액에 달하는 금액. 끝.

3. 채권압류명령 및 추심명령

가. 의 의

“압류명령”이란 제3채무자에 대하여 채무자에게 지급하는 것을 금하고, 채무자에 대하여 채권의 처분, 특히 그 추심을 해서는 안 된다고 명령하는 집행법원의 결정을 말한다(민사집행법 227조).

“추심명령”이란 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권을 대위의 절차(민법 제404조, 제405조)없이 추심할 권리를 직접 집행채권자에게 부여하는 명령을 말한다(민집법 제229조 제2항).

압류명령신청은 추심명령이나 전부명령과 별개이므로 압류명령만을 신청할 수 있다. 실무에서는 추심명령신청 또는 전부명령신청과 병합하여 신청하고 있다.

나. 요 건

채권압류명령 및 추심명령을 받은 압류채권자는 추심한 금전으로 다른 채권자가 없는 경우에는 자기의 변제에 충당하면 되나 절차에 참가한 다른 채권자가 있는 경우에는 민사집행법 제252조 이하의 배당절차에 의하여 배당받게 된다. 그러나 전부명령의 경우에는 다른 채권자가 배당요구를 할 수 없어 압류채권자가 독점적 만족을 받을 수는 있으나 이때 제3채무자가 경제력이 없는 때에는 전혀 만족 받을 수 없게 된다. 따라서 제3채무자가 경제력이 없을 때에는 추심명령을, 경제력이 있을 때에는 전부명령을 신청하는 것이 실익이 있을 것이다. 동시신청은 허용되지 아니하나 전술한 바와 같이 전부명령을 신청한 뒤 추심명령을 신청할 수 있고 일부채권에 대하여 추심명령을, 다른 일부채권에 전부명령을 신청할 수도 있다.

추심명령이 발하여 짐으로써 압류채권자는 채무자 대신 압류된 채권의 추심을 할 권한을 취득하게 되나 채무자는 여전히 압류된 채권의 채권자로 남아 있게 된다.

다. 채권압류명령 및 추심명령 신청절차

(1) 신 청

채권압류명령 및 추심명령신청은 서면으로 하여야 한다(민집법 제4조). 신청서에는 채권의 종류와 수액, 압류채권자가 대위절차 없이 피압류채권을 지급받을 수 있음을 명하는 재판을 구하는 취지를 구체적으로 명시하여야 한다. 피압류채권의 일부에 대하여 추심명령을 구하는 때에는 그 취지를 명확히 기재하여야 한다. 추심명령 신청은 압류명령의 신청과 동시에 할 수도 있고, 그 후에 신청할 수도 있다. 실무에서는 동시에 신청하고 있다.

압류명령의 신청과 함께 추심명령의 신청을 하는 경우에는 4,000원(압류명령 2,000원+추심명령 2,000원)의 인지를 붙인다(재민 91-1).

송달료는 당사자 1인당 2회분(1회분은 5,500원)을 납부하여야 한다.

신청서류는 신청서 1통, 압류명령원본 및 정본에 첨부할 당사자목록, 집행채권, 피압류채권목록은 원본 및 정본 수만큼 제출하여야 한다.

압류명령신청을 수개의 집행권원에 기하여 1개의 신청서로 신청하는 때에는 수개의 신청이므로 집행권원의 수에 상응하는 인지를 첨부하여야 하고, 다만 전부명령은 압류된 채권 전체가 하나로써 채권자에게 전부되는 것이므로 1개의 신청으로 취급한다(재민 87-9호).

(2) 관할법원

집행법원은 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원으로 하고(민집법 제224조 제1항), 그 지방법원이 없는 경우 집행법원은 제3채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원으로 한다. 다만, 이 경우에 물건의 인도를 목적으로 하는 채권과 물적 담보권 있는 채권에 대한 집행법원은 그 물건이 있는 곳의 지방법원으로 한다(민집법 제224조).

(3) 추심명령의 효력

채권압류명령 및 추심명령신청은 제3채무자에게 송달됨으로써 그 효력이 발생한다(민집법 제229조 제4항, 제227조 제3항). 따라서 채권자는 추심명령에

의하여 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권을 직접 추심할 권능을 가진다.

추심명령은 집행채권의 범위를 넘어 압류된 채권의 전액에 미친다(민집법 제232조 제1항 본문). 추심한 채권을 변제에 충당하고도 남으면 채무자에게 돌려줘야 한다.

추심명령의 효력은 압류후의 이자 및 지연손해금에도 미친다. 따라서 채무자는 압류된 채권이 채권자의 요구액보다 많을 때에는 압류액을 그 요구액으로 제한하여 줄 것을 신청할 수 있다.

(4) 압류명령의 효력 발생

압류명령이 효력을 발생하기 위해서는 목적채권이 존재하여야 한다. 따라서 선행압류가 있을 때에는 목적채권이 존재하였더라도 후행압류가 있을 당시에 이미 채권이 존재하지 않는다면 압류의 경합은 생기지 않는다.

금전채권에 대한 추심명령에 있어 집행법원이 채무자의 신청에 따라 압류액을 그 채권자의 요구액에 제한한 때에는 다른 채권자가 배당요구를 하지 못하므로(민집법 제232조 2항) 이 경우에도 이중압류는 발생하지 않는다.

또한 선행 압류채권자가 추심명령을 얻어 추심을 마쳤거나, 제3채무자가 공탁을 한 경우에도 압류된 채권은 소멸하므로 그 후 압류명령이 발령되어도 압류의 경합이 생기지 않는다. 다만 추심채권자가 추심신고(민집법 제236조 1항)를 하거나 제3채무자가 공탁사유신고(민집법 제248조 4항)를 할 때까지는 압류명령 신청으로서는 무효라고 하더라도 배당요구로서의 효력을 인정하는 것이 일반적이다.

선행의 압류가 이루어진 후에 목적채권이 제3자에게 양도되어 대항요건을 갖춘 다음에는 그 채무자에 대한 집행채권에 기초하여 다시 그 채권을 압류할 수 없으므로 압류의 경합은 생기지 않으며, 압류하더라도 배당요구의 효력도 인정되지 않는다. 배당요구의 종기(민집법 제247조 1항) 이후에 후행의 압류가 이루어진 때에는 그 압류채권자는 선행압류에 의한 배당절차에 가입하지 못하므로 압류의 경합은 생기지 않는다.

[서식] 채권압류 및 추심명령신청서(신탁수익금에 대한)

채권압류 및 추심명령신청

채 권 자 최 명 윤(주민등록번호)
서울 은평구 불광동 123 삼일빌라 가동 101호(우:)
(연락처)

채 무 자 문 조 영
서울 종로구 종로5가 12 태창빌라 101호 (우:)

제3채무자 서울○○신탁 주식회사
(수탁자) 서울시 서초구 서초동 123-4
대표이사 김 철 수
전화

청 구 금 액

1. 금27,000,000원정

서울중앙지방법원 20○○차4242호 차용금반환사건의 집행력 있는 지
급명령 정본에 의한 금원

2. 금684,000원

위 금원에 대한 20○○. 12. 14부터 20○○. 1. 21까지의 연 12%의
비율에 의한 지연손해금

3. 독촉절차비용 금71,460원정

내역 1. 금67,500원정 인지대

1. 금 3,960원정 송달료

합계금 27,755,460원정

압류 및 추심할 채권의 표시

별지목록 기재와 같음

신 청 취 지

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니된다.
4. 채권자는 채무자의 제3채무자에 대한 위 압류된 채권을 추심할 수 있다.

라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

1. 제3채무자인 서울○○신탁 주식회사는 채무자인 위탁자와 20○○. ○. ○ 신탁계약을 체결하고 같은 날 위탁자는 제3채무자에게 소유권 이전 및 신탁등기를 경료하였습니다. 제3채무자는 신탁설정 후 신탁 재산을 관리 처분해 오고 있으며, 신탁수익금으로 채무자에게 매월 금000원을 현금으로 지급하고 있습니다.
2. 채권자는 채무자에 대하여 서울중앙지방법원 20○○차4242호 집행력 있는 지급명령 정본에 의하여 채무자로부터 지급받을 금원이 위 청구금액 기재의 금원인바, 채무자는 지금까지 동 금원을 변제하지 않고 있으므로 위 청구금액에 대하여 변제를 받고자 부득이 채무자가 제3채무자에게 대하여 가지는 별지목록 기재 채권을 압류하고 추심을 하고자 이 신청에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|-------------------|----|
| 1. 집행력 있는 지급명령 정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |
| 1. 법인등기부등본 | 1통 |

1. 송달료납부서	1통
20〇〇. 1. .	
위 채권자 최 명 윤 (인)	
서울중앙지방법원 귀중	

[별지]

목 록
금 27,755,460원정
채무자가 제3채무자와 20〇〇. 〇. 〇. 서울시 〇〇구 〇〇로 00길0 대350㎡의 부동산을 신탁설정으로 인하여 제3채무자가 신탁재산을 관리·처분하고 있는바, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 신탁 수익금 청구채권 중 위 청구금액에 달하는 금액 끝.

4. 전부명령

가. 서 설

“전부명령”이란 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 압류한 금전채권을 집행채권과 집행비용청구권의 변제에 갈음하여 압류채권자에게 이전시키는 집행법원의 결정을 말한다. 추심명령과 전부명령은 압류채권자의 의사에 따라 둘 중 하나를 선택하여 할 수도 있고 추심명령을 얻은 채권에 대하여 사후에 전부명령을 신청할 수도 있다. 그러나 동시신청은 할 수 없다. 전부명령에 의할 경우의 이점은 다른 채권자가 배당요구를 할 수 없어 압류채권자가 독점으로 채무액을 변제받을 수는 있으나, 제3채무자가 경제력이 없는 경우에는 전혀 채권의 변제를 받을 수 없는 불이익을 당할 수도 있다. 그러므로 실무에서는 제3채무자가 자력이 확실한 경우에 전부명령을 신청하고 있다. 여기서는 추심명령에 있어서 상이한 점만 보기로 하고 그 외는 추심명령(553면 참조)을 참조하기로 한다.

나. 요 건

(가) 압류명령없이 전부명령을 할 수 없다. 그러므로 압류명령은 동시 또는 선행되어야 한다. 압류명령신청을 위하여는 강제집행의 요건을 갖추어야 하는 것은 압류명령신청란에서 보았다. 따라서 강제집행의 요건을 갖추지 아니한 전부명령에 대하여는 즉시항고로 배척할 수 있다(민집법 제229조 제6항).

(나) 양도할 수 없는 채권은 현금화가 불가능하므로 압류도 할 수 없다.

(다) 경합이 없어야 한다. 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 다른 채권자가 압류·가압류 또는 배당요구를 한 때에는 전부명령은 효력이 없다(민집법 제229조 제5항). 그러나 전부명령의 기초가 되었던 압류명령까지 무효가 되는 것은 아니므로, 무효인 전부명령을 얻었던 압류채권자도 위의 압류명령에 기하여 추심명령을 얻을 수 있다(대법원 1976.9.28. 선고 76다1145, 1146 판결). 따라서 이를 대비하여 추심명령도 신청해 두는 것이 이익이다. 그러나 동일한 채권에 대하여 중복압류 등이 있더라도 그 압류등의 채권액을 합산하더라도 총채권에 미치지 아니할 때에는 그 나머지 부분에 한 전부명령은 유효하다(대법원 1979.6.5.자 79마715 결정).

(라) 금전채권이 아닌 채권은 피전부채권이 될 수 없어 전부명령의 대상이 될 수 없다(대법원 1979.12.11. 선고 79다1487 판결).

다. 전부명령신청절차

(1) 신청방식

이 신청은 서면으로 하여야 한다(민집법 제4조). 신청은 압류명령의 신청과 동시에 할 수도 있고 그 후에 신청할 수도 있으나 실무에서는 동시에 신청하고 있다. 추심명령을 얻은 채권에 대하여 다시 전부명령을 신청할 수도 있다. 전부명령신청의 경우에는 압류채권 일부에 대하여는 신청할 수 없다.

가압류가 된 채권의 경우에는 가압류채권자가 집행권원을 얻었다라도 바로 전부명령을 신청할 수는 없고 채권압류명령신청과 함께 하여야 한다. 이 압류명령신청에 의하여 가압류는 본압류로 이전한다. 전부명령만을 별도로 신청하는 경우에는 선행의 채권압류명령사건의 번호가 있어야 한다. 이밖의 내용 및 첨부서류, 관할법원은 추심명령의 경우와 같다.

(2) 첨부인지 등

① 압류명령만을 신청하는 경우에는 민사소송등 인지법 제9조 제3항 제1호에 의하여 2,000원을, 압류명령과 동시에 신청하는 경우에는 4,000원을 붙인다.

② 수개의 집행권원에 기하여 1건의 신청으로 채권압류 및 전부명령을 신청한 경우, 압류명령은 수개의 신청을 편의상 1건으로 신청한 것이므로 집행권원의 수에 상응하는 인지를 붙여야 하고, 전부명령은 수개의 압류된 채권 전체가 하나로써 채권자에게 전부되는 것이므로 1건으로 취급하여 2000원의 인지를 붙여야 한다(재민 87-9).

송달료는 당사자 1인당 2회분(1회분은 5,500원)을 납부하여야 한다.

신청서류는 신청서 1통, 압류명령원본 및 정본에 첨부할 당사자목록, 집행채권, 피압류채권목록은 원본 및 정본 수만큼 제출하여야 한다.

압류명령신청을 수개의 집행권원에 기하여 1개의 신청서로 신청하는 때에는 수개의 신청이므로 집행권원의 수에 상응하는 인지를 첨부하여야 하고, 다만 전

부명령은 압류된 채권 전체가 하나로써 채권자에게 전부되는 것이므로 1개의 신청으로 취급한다(재민 87-9호).

(3) 압류의 경합

선행 압류채권자가 전부명령을 얻은 경우에는 그 전부명령이 제3채무자에게 송달되기 전에 다른 채권자의 압류명령이 제3채무자에게 송달된 때에는 압류의 경합이 발생하지만(민집법 제229조 5항), 전부명령이 제3채무자에게 송달된 뒤에는 비록 확정되기 전에 다른 압류명령이 있더라도 선행의 전부명령이 실효되지 않는 한 압류의 경합은 생기지 않는다.⁹⁵⁾

한편 장래의 불확정채권에 대하여 압류가 중복된 상태에서 전부명령이 있는 경우 그 압류의 경합으로 인하여 전부명령이 무효가 되는지의 여부는 나중에 확정된 피압류채권액을 기준으로 판단할 것이 아니라 전부명령이 제3채무자에게 송달된 당시의 계약상의 피압류채권액을 기준으로 판단하여야 하고(대법원 1998. 8. 21. 선고 98다15439 판결), 장래의 불확정채권에 대한 전부명령을 허용하는 것은 가까운 장래에 채권이 발생할 것이 상당한 정도로 기대되기 때문이므로, 전부명령 송달 당시 피압류채권의 발생 원인이 되는 계약에 그 채권액이 정해지지 아니하여 그 채권액을 알 수 없는 경우에는 그 계약의 체결 경위와 내용 및 그 이행 경과, 그 계약에 기하여 가까운 장래에 채권이 발생할 가능성 및 그 채권의 성격과 내용 등 제반 사정을 종합하여 그 계약에 의하여 장래 발생할 것이 상당히 기대되는 채권액을 산정한 후 이를 그 계약상의 피압류채권액으로 봄이 상당하다(대법원 2010.5.13. 선고 2009다98980 판결).

95) 법원행정처 발행 실무제요 민사집행 III 404쪽

[서식] 채권압류 및 전부명령신청서(신탁 수익금에 대한)

채권압류 및 전부명령신청

채 권 자 구 충 서(주민등록번호)
서울 종로구 창신동 12(우:)
(연락처)

채 무 자 오 근 모
서울 중구 서소문동 13(우:)

제3채무자 서울○○신탁 주식회사
(수탁자) 서울시 서초구 서초동 123-4
대표이사 김 철 수
전화

청구채권의 표시

금50,000,000원정

서울중앙지방법원 20○○가합1892호(서울고등법원 20○○나1855호,
대법원 20○○다카2545호) 사건의 집행력 있는 판결정본에 기한 보증채
무금 청구채권

압류 및 전부할 채권의 표시

별지목록 기재와 같음

신 청 취 지

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니된다.

3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니된다.
4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채권자에게 전부한다.
라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

1. 제3채무자인 서울○○ 신탁 주식회사는 채무자인 위탁자와 20○○. ○. ○ 신탁계약을 체결하고 같은 날 위탁자는 제3채무자에게 소유권 이전 및 신탁등기를 경료하였습니다. 제3채무자는 신탁설정 후 신탁재산을 관리 처분해 오고 있으며, 신탁수익금으로 채무자에게 매월 금 000원을 현금으로 지급하고 있습니다.
2. 채권자는 채무자에 대하여 서울중앙지방법원 20○○가합1892호 보증채무금(서울고등법원 20○○나1855호, 대법원 20○○다카2545호)사건의 집행력있는 판결정본에 의한 위 청구금액 표시의 채권 금 50,000,000원을 가지고 있습니다.
3. 채무자는 채권자에게 위 금원을 변제하여야 할 의무가 있음에도 이를 지불치 아니하므로, 채권자는 채무자가 제3채무자로부터 수령할 별지 목록 기재 청구채권을 압류하는 동시에 전부할 수 있는 취지의 명령을 구하기 위하여 이 신청에 이른 것입니다.

소명 및 첨부서류

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 집행력있는 판결정본 | 1통 |
| 1. 확정증명원, 송달증명원 | 각1통 |
| 1. 신탁원부 | 1통 |
| 1. 법인등기부등본 | 1통 |
| 1. 송달료납부서 | 1통 |

20〇〇. 12. .

위 채권자 구 충 서 (인)

서울중앙지방법원 귀중

[별지]

목 록

금 27,755,460원정
채무자가 제3채무자와 20〇〇. 〇. 〇. 서울시 〇〇구 〇〇로 00길0 대350 m²의 부동산을 신탁설정으로 인하여 제3채무자가 신탁재산을 관리·처분하고 있는바, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 신탁 수익금 청구채권 중 위 청구금액에 달하는 금액 끝.

제3관 사해신탁을 원인으로 한 보전처분

1. 서 설

부동산신탁은 신탁의 목적 범위 내에서 신탁계약에 정하여진 바에 따라 관리·처분되므로 신탁법은 특별규정을 두어 일정한 목적의 신탁을 제한하였다. 따라서 신탁법은 ①선량한 풍속 기타 사회질서(민법 제103조)에 반하는 신탁(신탁법 제5조), ②소송을 목적으로 하는 신탁(신탁법 제6조) ③탈법행위를 목적으로 하는 신탁(신탁법 제7조)의 경우에는 이를 사해신탁이라 하여 채권자는 수탁자가 선의일지라도 채권자취소권(민법 제406조)을 적용하여 신탁의 취소 및 원상회복을 청구할 수 있도록 하였다(신탁법 제8조).

위와 같이 신탁법은 그 목적이 위법 또는 불능한 때에는 무효라고 규정하고, 탈법을 목적으로 하는 신탁을 금지하고 있는바, 이러한 규정의 취지는 재산권을 향유할 수 있는 자격이 없는 사람이 이를 회피하여 그 수익자격을 얻기 위한 방편으로 신탁이 이용되는 것을 막고자 함에 있다. 다음에서 차례로 본다.

2. 신탁목적의 제한

가. 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 신탁

(1) 법조문

신탁법 제5조는 “(목적의 제한) ① 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 위반하는 사항을 목적으로 하는 신탁은 무효로 한다. ② 목적이 위법하거나 불능인 신탁은 무효로 한다. ③ 신탁 목적의 일부가 제1항 또는 제2항에 해당하는 경우 그 신탁은 제1항 또는 제2항에 해당하지 아니한 나머지 목적을 위하여 유효하게 성립한다. 다만, 제1항 또는 제2항에 해당하는 목적과 그렇지 아니한 목적을 분리하는 것이 불가능하거나 분리할 수 있더라도 제1항 또는 제2항에 해당하지 아

니한 나머지 목적만을 위하여 신탁을 유지하는 것이 위탁자의 의사에 명백히 반하는 경우에는 그 전부를 무효로 한다.”고 규정하였다.

구법은 “선량한 풍속 및 사회질서에 반하는 목적을 신탁의 목적으로 할 수 없다”고만 규정하여 규정형식상 선량한 풍속 등에 반하는 신탁의 효력에 대한 언급이 없었다. 따라서 민법 제103조와 마찬가지로 당연 무효로 보아야 하므로 개정 신탁법에서는 그 취지를 명백히 하여 “무효로 한다”는 문구를 추가한 것이다.

(2) 사회질서에 반하는 신탁⁹⁶⁾

신탁의 목적은 사법상의 일반원칙에 따라 확정성, 사회의 타당성, 가능성, 적법성의 요건을 갖추어야 한다. 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 반하는 목적의 신탁은 절대적 무효이기 때문에 추인에 의하여 유효로 될 수 없다.

‘선량한 풍속’, ‘사회질서’의 의미 및 유형은 민법 제103조의 해석에 따른다. 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 위반하는지 여부는 원칙적으로 신탁행위당시를 기준으로 판단하여야 한다.⁹⁷⁾

(3) 목적이 위법하거나 불능인 신탁⁹⁸⁾

신탁의 목적은 실현이 가능하여야 하고 목적의 실현이 불가능한 신탁은 무효로 한다. 여기서의 실현가능성은 신탁행위를 할 당시에 이미 실현이 불가능한 ‘원시적 불능’에 한정되나, 실현이 불가능한 원인은 한정되지 않아서 물리적 원인, 법률적 원인뿐만 아니라 사회관념상의 원인에 의한 실현 불가능성도 포함한다.

신탁은 강행규정에 위반되는 내용을 목적으로 설정할 수 없고, 일반 법률행위

96) 법무부 발행 신탁법 해설 57쪽

97) 매매계약체결 당시에 정당한 대가를 지급하고 목적물을 매수하는 계약을 체결하였다면, 비록 그 후 목적물이 범죄행위로 취득된 것을 알게 되었다고 하더라도, 계약의 이행을 구하는 것 자체가 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 것으로 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 그러한 사유만으로 당초의 매매계약에 기하여 목적물에 대한 소유권이전등기를 구하는 것이 민법 제103조의 공서양속에 반하는 행위라고 단정할 수 없다(대법원 2001. 11. 9. 선고 2001다44987 판결).

98) 법무부 발행 신탁법 해설 58쪽

와 달리 해당 강행규정이 사법상 효과가 부정되는 효력규정인지 단순한 행정상 금지법규인 단속규정인지 여부와 관계없이 무효이다.⁹⁹⁾

(4) 목적 중 일부가 무효인 신탁의 효력¹⁰⁰⁾

신탁의 목적 중 일부가 무효인 경우, 원칙적으로 나머지 목적만으로 신탁은 유효하게 성립하나, 예외적으로 유효한 목적만으로는 신탁이 성립되지 않거나 (분할가능성 요건 흠결), 유효한 목적 부분만으로 신탁성립을 인정하는 것이 위탁자의 의사에 명백하게 반하는 경우에는 무효이다. 법률행위의 일부가 무효인 경우의 효과에 대한 일반규정인 민법 제137조¹⁰¹⁾에 대한 특별규정이다(신탁법 제5조 제3항).

나. 소송을 목적으로 하는 신탁

(1) 법조문

신탁법 제6조는 “(소송을 목적으로 하는 신탁의 금지) 수탁자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 신탁은 무효로 한다.”고 규정하였다.

본조는 소송행위를 할 수 없는 권리를 가진자가 신탁의 형식을 이용하여 수탁자로 하여금 타인의 분쟁에 관여하여 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 하는 신탁의 설정을 무효로 규정한 것이다.

(2) 소송신탁의 판단 기준

소송신탁에서의 소송행위란 민사소송법상의 소송행위에 한정되지 않고 널리 사법기관을 통하여 권리의 실현을 도모하는 행위를 말하는 것으로서 민사집행법에 의한 강제집행의 신청도 이에 포함된다(대법원 2010.1.14. 선고 2009다55808 판결).

99) 이중기 : 신탁법 61쪽 각주52)

100) 법무부 발행 신탁법 해설 59쪽

101) 제137조 【법률행위의 일부무효】 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다.

소송을 주목적으로 신탁한 것인지 여부를 정함에 있어서는 수탁자가 반드시 직접 소송을 수행함을 요하지 아니하고 소송대리인에게 위임하는 경우에도 이를 인정할 수 있다 할 것이다(대법원 2006.6.27. 선고 2006다463 판결).

소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 할 것인바(대법원 2004. 6. 25. 선고 2004다8371 판결, 대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결), 위와 같은 법리는 토지의 점유·사용으로 인한 부당이득반환청구의 소를 제기할 목적으로 그 토지에 관하여 소유권이전등기를 경료한 경우에도 마찬가지로 적용된다 할 것이고(대법원 1970. 3. 31. 선고 70다55 판결), 수표의 경우 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 추심위임배서에 이르게 된 경위와 방식, 추심위임배서가 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 배서인과 피배서인 간의 신분관계 등 여러 상황에 비추어 판단하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다20909, 20916 판결, 대법원 2007.12.13. 선고 2007다53464 판결).

(3) 소송신탁의 인부(認否)

(가) 소송신탁에 해당된다고 한 사례

① 부부 사이의 채권양도행위

부부 사이의 채권양도가 소송행위를 하게 함을 주목적으로 하는 신탁에 해당하여 무효라고 본 사례이다(대법원 1996. 3. 26. 선고 95다20041 판결).

② 토지에 관한 소유 명의를 타인에게 이전하고, 그 토지의 점유·사용에 따른 부당이득반환채권을 양도한 경우

지방자치단체에 의하여 도로로 점유·관리되어 온 토지의 소유권자가 그 토지에 관한 소유 명의를 타인에게 이전하고, 그 토지의 점유·사용에 따른 부당이득반환채권을 양도한 것이 그 타인의 명의로 위 지방자치단체에 대한 차임 상당의 부당이득반환청구의 소를 제기하기 위한 목적으로 이루어진 것이라고 봄이 상

당하다는 이유로 소송신탁에 해당되어 무효라고 보았다(대법원 2006.6.27. 선고 2006다463 판결).

③ 소송신탁의 법리를 오해한 위법이 있다는 이유로 파기한 사례

점유취득시효의 항변을 받자 소송을 취하한 후 원고를 달리하여 다시 동일한 내용의 토지인도청구소송이 제기되었지만 소송신탁이 아니라고 본 원심판결을, 원고 앞으로 소유권이전등기가 경료된 경위, 다시 제소하기에 이르기까지의 시간적 간격, 원고와 전소송당사자와의 신분관계 등 제반 정황에 비추어 심리미진 내지 소송신탁의 법리를 오해한 위법이 있다는 이유로 파기한 사례이다(대법원 1991.11.12. 선고 91다26522 판결).

④ 매수동기나 자금의 출처가 불분명한 점 등을 들어 무효라 한 사례

토지소유자 갑의 토지점유자인 시를 상대로 한 부당이득금반환청구소송 계속 중에 원고가 갑으로부터 매매를 원인으로 한 소유권이전등기를 경료받았으나, 당시 원고가 위 소송에서 시가 점유취득시효를 주장하고 있음을 알고 있어서 매매등 정상적인 거래가 이루어진다는 것은 이례적인 일이고 위 등기 경료 후에도 갑이 위 소송에서 원고로서의 지위를 그대로 유지하면서 계속 소유권자로 행세하였으며, 갑의 패소판결이 확정된 후 원고가 갑의 물상보증인이 되어 근저당권 설정등기를 경료하여 주었고, 위 소송에서 시가 취득시효의 항변만을 한 채 보전처분을 하지 아니하여 그 항변이 받아들여지더라도 소유권이 제3자에게 이전되면 그에 대항할 수 없었던 상황이었으며, 원고의 매수동기나 그 자금의 출처가 불분명한 점 등에 비추어 보면 원고 앞으로 경료된 위 소유권이전등기는 그로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 하는 신탁의 방법으로 이루어진 것으로 추인되므로 무효라 할 것이다(광주고법 1991.4.16. 선고 89나6517 판결).

⑤ 양도계약이 체결된 경위와 방식, 소송과 관련된 제3자의 행적 등 제반 상황 등

공사의 수급인이 건축중인 도급인 소유의 주택 및 부지를 매수한 후 공사대금을 지급받을 목적으로 제3자와 그 매매계약상 권리 및 의무를 양도하기로 하는 계약을 체결한 사안에서, 수급인과 제3자 사이에 양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약시부터 단기간 내에 소송이 제기된 점, 소송과 관련된 제3자의 그간의 행적 등 제반 상황에 비추어 볼 때, 수급인과 제3자 사이의 양도계약은 진정한 의미에서의 권리의 양도·양수가 아니라 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 신탁으로서 무효라고 보아야 한다(대법원 1997. 5. 16. 선고 95다 54464 판결).

⑥ 수탁자가 승소확정판결을 받아 지급 받은 채무금

소송신탁은 법률이 금하는 것이므로 채권자가 소외 망인으로 하여금 원고가 되어서 채무자에게 대여금청구소송을 제기하여 채권을 추심토록 의뢰한 약정은 반사회질서의 법률행위로서 무효이며 채권자는 소외 망인이 채무자에 대하여 대여금채권을 갖고 있는 것처럼 꾸며 소송을 제기하게 하고 채권자가 소지하고 있는 당좌수표를 증거로 제출할 수 있도록 교부하고 나아가 법정에서 허위의 증언을 함으로써 법원을 기망하여 승소확정판결을 받아 채무금을 지급받게 하였다면 채권자는 스스로 공동불법행위자임에도 불구하고 무효인 약정을 바탕으로 하고 또 스스로 불법행위를 자행한 자로서 약정에 의한 또는 부당이득에 의한 금원의 지급을 구하거나 소송사기에 의하여 채무자가 소송수탁자에 대하여 갖는 손해배상채권의 양도를 내세워서 손해의 배상을 구하는 것은 사회질서에 반할 뿐 아니라 신의칙에 반하는 것이다(대법원 1983.5.24. 선고 82다카1919 판결).

⑦ 수표의 배서양도가 피배서인으로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 소송신탁에 해당하여 무효라고 한 사례

수표의 수취인이 발행인과의 분쟁으로 인한 인적 항변에 의하여 수표금을 지급받지 못하게 될 것이 예상되자 제3자를 통한 소제기로 승소판결을 받아 수표금을 지급받기 위하여 제3자를 피배서인으로 하여 수표의 배서양도를 한 경우,

이러한 배서는 제3자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 소송신탁에 해당하여 무효이다(대법원 2007.12.13. 선고 2007다53464 판결).

⑧ 토지 매매 및 부당이득반환청구권 양도·양수

소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권 양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제7조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 채소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다20909, 20916 판결 등).

⑨소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제7조(개정 신탁법 제6조)가 유추적용되므로 무효이다(대법원 1969. 7. 8. 선고 69다362 판결, 1996. 3. 26. 선고 95다20041 판결).

(나) 소송신탁에 해당되지 않는다고 한 사례

어떤 행위가 신탁행위일지라도 그 신탁목적이 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이 아니면 소송신탁으로서 금지되는 것은 아니다. 여기에 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이라고 함은 소송행위를 하게 하는 것 자체가 그 신탁목적의 주요한 부분을 구성하는 것이다. 그러므로 신탁사무처리의 과정에서 수탁자가 우연히 또는 부수적으로 소송행위를 하는 경우에는 이를 신탁법이 무효로 보는 소송신탁이라고 할 수는 없다.¹⁰²⁾

또한 채권의 추심위임을 받은 자는 의뢰인과 동일한 법률상의 지위 및 소송상의 권리를 가지고 있고, 추심에 관하여 자기의 이름으로 소송을 제기하여도 소송을 주목적으로 하는 추심위임이 아니면 본조의 적용이 없다. 따라서 추심을 위하여 채권양도를 하였다고 하여 이러한 사실만으로 당연히 소송신탁이라고 인정할 것이 아니다. 추심의 방법을 소송의 방법에 의하게 하는 것을 주목적으

102) 허규 전계논문 59쪽.

로 하는 경우에만 해당하는 것이다.¹⁰³⁾

① 채권양도

다수의 채권자가 채권자단의 대표에게 자신들의 채권을 양도하고 그 양도된 채권을 피담보채권으로 한 근저당권을 양수인 명의로 설정받은 경우, 다수 당사자가 권리를 행사하는 불편함을 없애고 채권의 효율적인 회수를 하기 위하여 채권양도를 한 점, 채권양도 및 근저당권설정등기 일자와 근저당권에 기한 임의경매신청 일자 사이의 시간적 간격이 약 2년으로 비교적 길었던 점, 채무자들도 양도인과 양수인 사이의 위와 같은 약정을 용인하고 합의당사자가 되었던 점 등 제반 사정에 비추어 그 채권양도는 소송행위를 하게 하는 것이 주목적이었다고 볼 수 없다(대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결).

② 업무집행 조합원에 대한 임의적 소송신탁의 적부

민사소송중 재산권상의 청구에 관하여는 소송물인 권리 또는 법률관계에 관하여 관리처분권을 갖는 권리주체에게 당사자적격이 있다고 함이 원칙이나 비록 제3자라고 하더라도 법률이 정하는 바에 따라 일정한 권리나 법률관계에 관하여 당사자적격이 부여되는 경우와 본래의 권리주체로부터 그의 의사에 따라 소송수행권을 수여 받음으로써 당사자적격을 인정하는 경우도 허용된다고 풀이할 것이다. 물론 이와 같은 임의적 소송신탁은 우리나라 법제하에서는 그 허용되는 경우라는 것은 극히 제한적이라고 밖에 할 수 없을 것이나 탈법적 방법에 의한 것이 아니고(소송대리를 변호사에 한하게 하고 소송신탁을 금지하는 것을 피하는 따위)이를 인정하는 합리적 필요가 있다고 인정되는 경우가 있을 것이므로 따라서 민법상의 조합에 있어서 조합규약이나 조합결의에 의하여 자기의 이름으로 조합재산을 관리하고 대외적 업무를 집행할 권한을 수여받은 업무집행 조합원은 조합재산에 관한 소송에 관하여 조합원으로부터 임의적 소송신탁을 받아 자기의 이름으로 소송을 수행하는 것은 허용된다고 할 것이다(일찌기 당원

103) 소송신탁의 판단기준 및 임의적 소송담당의 허용한계 - 대상판결 : 대법원 2002.12.6. 선고, 2000다4210 판결 윤 경

이 1968.2.27. 선고 67다2104, 2105 판결에서 밝힌 “만일 위와 같은 반소원고들의 반소청구가 위 조합의 원고에 대한 채권을 행사한 것이라면 위의 조합에 있어서의 조합계약에 그 업무집행자에 관한 규정이 있는가의 여부와 그와 같은 규정이 없다면 반소원고들은 위 조합의 업무집행자로 선출되었는가의 여부 및 과연 본건과 같은 원고에 대한 조합의 채권을 행사하는 것이 위 조합의 상무에 속하는 것인가의 여부의 점들을 석명하고 심리판단을 하여야 한다”는 판시는 민법상의 조합에 있어서의 이와 같은 임의적 소송신탁이 허용될 것임을 전제로 하는 것으로 새겨진다). (대법원 1984.2.14. 선고 83다카1815 판결)

③ 조합재산에 관한 임의적 소송신탁

민법상 조합의 채권은 조합원 전원에게 합유적으로 귀속하는 것이어서 특별한 사정이 없는 한 조합원 중 1인에 대한 채권으로써 그 조합원 개인을 집행채무자로 하여 조합의 채권에 대하여 강제집행을 할 수 없고(대법원 1997. 8. 26. 선고 97다4401 판결), 조합 업무를 집행할 권한을 수여받은 업무집행 조합원은 조합재산에 관하여 조합원으로부터 임의적 소송신탁을 받아 자기 이름으로 소송을 수행할 수 있다(대법원 1997. 11. 28. 선고 95다35302 판결, 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다68924 판결).

④ 채권양도가 소송신탁에 해당하는지 여부

금원 갈취 피해자가 한 채권양도통지에 강박에 의한 증여 취소의 의사표시가 묵시적으로 포함되었다고 볼 수 있지만, 채권양도가 소송신탁에 해당하여 무효이고 이에 기한 양도통지 또한 무효인 이상 위 취소의 의사표시만을 유효하다고 볼 수 없다(대법원 2009.10.15. 선고 2008다88832 판결).

3. 탈법을 목적으로 하는 신탁

가. 개 설

개정 신탁법 제7조는 “(탈법을 목적으로 하는 신탁의 금지) 법령에 따라 일정한 재산권을 향유할 수 없는 자는 수익자로서 그 권리를 가지는 것과 동일한 이익을 누릴 수 없다.”고 규정하고 있다.

본조는 신탁제도를 이용하여 특별권리능력에 관한 강행규정을 직접 위반하지 아니하더라도 실질적으로 강제규정에 반하여 그 목적을 달성하려는 행위를 정책적인 차원에서 막기 위한 규정이다.

나. 탈법신탁의 판단

무효인 탈법신탁에 해당하는지 여부는 당해 강행규정의 취지, 신탁의 목적, 수익권의 내용 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.¹⁰⁴⁾

일단 유효하게 성립한 신탁에 있어서도 본조에 해당하는 사유가 발생한 때에는 그 사유가 해소하지 아니하는 한 신탁은 종료한다.¹⁰⁵⁾

다. 법령에 의하여 일정한 재산권을 향유할 수 없는 자

법령에 의해 일정한 재산권을 향하는 것이 금지되어 있는 자는 신탁의 수익자가 됨으로써 사실상 그 재산권을 향유하는 것과 동일한 이익을 얻을 수 없으며 이러한 신탁은 무효이다. 개정 신탁법에서는 제11조가 미성년자, 금치산자, 한정치산자 및 파산선고를 받은 자는 수탁자가 될 수 없다고 규정하고 있다. 이외에 외국인토지법 제3조, 광업법 제10조의2, 선박법 제2조, 저작권법 제3조 등에서 외국인에 한하여 제한하고 있다.

외국인이 장차 토지에 대한 권리에 필요한 요건이 구비되었을 때 취득할 것을 내용으로 한 채권관계 설정행위에 관하여 판례는 “외국인이 토지에 대한 권리를 대통령령에 따르는 내무부장관의 허가없이 취득하기 위해서 또는 소유권자와

104) 최수정, 일본 신탁법 22쪽

105) 홍유석 신탁법 법문사 91쪽

동일한 이익을 받기 위해서가 아니고 단순히 장차 그 요건 구비시에 취득한 것을 내용으로 한 채권관계설정행위는 외국인토지법 제5조 제5조의3, 제13조 또는 신탁법 제5조, 6조의 각 취지에 어긋나는 것이라고 할 수 없고 또 위와 같은 채권설정정행위가 공서양속에 위반되는 행위가 공서양속에 위반되는 행위라고도 할 수 없다(대법원 1975. 12. 23. 선고 73도3012 판결).”고 한 판례가 있다.

4. 사해신탁

가. 개 설

(1) 의 의

“사해신탁”은 위탁자가 채권자를 해하기 위하여 설정한 신탁으로, 민법 제406조의 채권자 취소권을 신탁법에 대해서도 적용되는 경우의 특칙을 규정한 것이다.

신탁법상의 사해행위취소제도는 위탁자가 변제자력이 없을 정도로 많은 채무를 지고 있음에도 불구하고 “신탁전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우(신탁법 제22조 제1항 단서)” 이외에는 신탁재산에 대하여 강제집행 또는 경매를 할 수 없도록 규정한 것을 이용, 자신의 채무를 면탈하기 위하여 신탁제도를 악용하는 것을 방지한다는 점에서 그 제정이유가 있다고 하겠다.

신탁법 제8조(사해신탁) ① 채무자가 채권자를 해함을 알면서 신탁을 설정한 경우 채권자는 수탁자가 선의일지라도 수탁자나 수익자에게 「민법」 제406조제1항의 취소 및 원상회복을 청구할 수 있다. 다만, 수익자가 수익권을 취득할 당시 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 경우에 여러 명의 수익자 중 일부가 수익권을 취득할 당시 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 악의의 수익자만을 상대로 제1항 본문의 취소 및 원상회복을 청구할 수 있다.

③ 제1항 본문의 경우에 채권자는 선의의 수탁자에게 현존하는 신탁재산의 범

위 내에서 원상회복을 청구할 수 있다.

④ 신탁이 취소되어 신탁재산이 원상회복된 경우 위탁자는 취소된 신탁과 관련하여 그 신탁의 수탁자와 거래한 선의의 제3자에 대하여 원상회복된 신탁재산의 한도 내에서 책임을 진다.

⑤ 채권자는 악의의 수익자에게 그가 취득한 수익권을 위탁자에게 양도할 것을 청구할 수 있다. 이때 「민법」 제406조제2항을 준용한다.

⑥ 제1항의 경우 위탁자와 사해신탁(詐害信託)의 설정을 공모하거나 위탁자에게 사해신탁의 설정을 교사·방조한 수익자 또는 수탁자는 위탁자와 연대하여 이로 인하여 채권자가 받은 손해를 배상할 책임을 진다.

(2) 사해성의 판단

(가) 개 설

사해성의 존재 여부는 개별 사안에 따라 판단하여야 하며, 「민법」 상 채권자 취소권의 ‘사해성’과 동일한 의미이므로 채권자취소권에 대한 논의가 적용된다.¹⁰⁶⁾

신탁행위에 사해성이 있는지 여부가 위탁자가 채무초과 상태에서 해당 신탁 설정행위로 인하여 위탁자 명의의 책임재산 또는 공동담보가 감소되었다는 형식적인 측면만을 보아서는 아니되고, 실질적으로 책임재산이 증감되었는지, 즉 신탁이 책임재산의 감소나 공동담보의 부족을 초래하였는지 여부를 고려하여야 한다.

“채권자를 해 한다”는 것, 즉 사해성이란, 위탁자의 신탁설정행위로 위탁자의 총재산이 감소되어 채권의 공동담보에 부족이 생기거나 이미 부족상태에 있는 공동담보가 한층 더 부족하게 됨으로써 채권자의 채권을 완전하게 만족시킬 수 없는 상태, 즉 채무자의 소극재산이 적극재산보다 많아지거나 그 정도가 심화되는 것을 의미한다.

판례는 “채무자의 사해의사를 판단함에 있어 사해행위 당시의 사정을 기준으

106) 임채웅 사해신탁의 연구 23쪽

로 하여야 할 것임은 물론이나, 사해행위라고 주장되는 행위 이후의 채무자의 변제 노력과 채권자의 태도 등도 사해의사의 유무를 판단함에 있어 다른 사정과 더불어 간접사실로 삼을 수도 있다(대법원 2003. 12. 12. 선고 2001다57884 판결).”고 한 것이 있고, “당사자 사이에 일련의 약정과 그 이행으로 최종적인 법률행위를 한 경우, 일련의 약정과 최종적인 법률행위를 동일한 법률행위로 평가할 수 없다면, 일련의 약정과 는 별도로 최종적인 법률행위에 대하여 사해행위의 성립 여부를 판단하여야 하고, 이때 동일한 법률행위로 평가할 수 있는지는 당사자가 같은지 여부, 일련의 약정에서 최종적인 법률행위의 내용이 특정되어 있거나 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있는지 여부, 조건 없이 최종적인 법률행위가 예정되어 있는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다53437 판결).”고 하였다.

또한 판례는 “채무자가 채무를 변제하지 아니한 채 그의 유일한 재산인 부동산에 관하여 제3자와 사이에 신탁계약을 체결하고 그 제3자 명의로 소유권이전 등기를 경료한 경우, 그 신탁계약은 채권자를 해함을 알고서 한 사해행위라고 봄이 상당하다(대법원 1999. 9. 7. 선고 98다41490 판결).”고 판시하였다.

(나) 선의 악의 판단

사해신탁은 수탁자의 악의를 요하지 않으며 수탁자가 선의이더라도 그 취소를 구할 수 있다. 선의의 판단시기에 대하여 구 신탁법은 “수익권을 통하여 이익을 받은 때”로 규정하고 있으나, 개정 신탁법에서는 “수익권을 취득한 때”로 하였다.

수익자가 악의라는 점에 대하여는 그 수익자 자신에게 선의임을 증명할 책임이 있다(대법원 2010.2.25. 선고 2007다28819,28826 판결). 수익자의 악의는 추정되므로 수익자로서는 자신의 책임을 면하려면 자신의 선의를 입증할 책임이 있다 할 것인데, 이 경우 수익자의 선의 여부는 채무자와 수익자의 관계, 채무자와 수익자 사이의 처분행위의 내용과 그에 이르게 된 경위 또는 동기, 그 처분행위의 거래조건이 정상적이고 이를 의심할만한 특별한 사정이 없으며 정상적인 거래관계임을 뒷받침할만한 객관적인 자료가 있는지 여부, 그 처분행위

이후의 정황 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 논리칙·경험칙에 비추어 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2008.7.10. 선고 2007다74621 판결).

사해행위 당시 수익자가 선의였음을 인정함에 있어서는 객관적이고도 납득할 만한 증거자료 등에 의하여야 하고, 채무자의 일방적인 진술이나 제3자의 추측에 불과한 진술 등에만 터 잡아 그 사해행위 당시 수익자가 선의였다고 선뜻 단정하여서는 안 된다(대법원 2006.7.4. 선고 2004다61280 판결).

나. 사해신탁의 취소 및 원상회복 청구

(1) 개 설

채무자가 채권자를 해함을 알면서 신탁을 설정한 경우 채권자는 수탁자가 선의일지라도 수탁자나 수익자에게 민법 제406조제1항(채권자취소권)의 취소 및 원상회복을 청구할 수 있다(신탁법 제8조제1항 본문). 이 경우 채권자는 선의의 수탁자에게 현존하는 신탁재산의 범위 내에서 원상회복을 청구할 수 있다(신탁법 제8조제3항). 다만, 수익자가 수익권을 취득할 당시 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 그렇지 아니한다. 이 경우 여러 명의 수익자 중 일부가 수익권을 취득할 당시 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 악의의 수익자만을 상대로 취소 및 원상회복을 청구할 수 있다(신탁법 제8조제1항 단서 및 제2항).

(2) 피보전채권

피보전채권은 금전채권이어서 한다. 대법원은 금전채권이 아닌, 매매로 인한 대지의 지분권에 관한 소유권이전등기를 구하는 사건에서, “신탁법 제8조 소정의 사해신탁의 취소는 민법상의 채권자취소권과 마찬가지로 책임재산의 보전을 위한 것이므로 피보전채권은 금전채권이어서 하고, 특정물에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 행사하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001다32236 판결).”라고 판시 하였다.

피보전권리는 원칙적으로 사해신탁행위 이전에 발생하고 있어야하나, 채권자취소권과 같이 예외적으로 ① 사해신탁행위 당시에 이미 채권 성립의 기초가 되는 법률관계가 발생되어 있고, ② 가까운 장래에 그 법률관계에 터잡아 채권이

성립되리라는 점에 대한 고도의 개연성이 있으며, ③ 실제로 가까운 장래에 그 개연성이 현실화되어 채권이 성립된 경우에는 그 채권도 피보전채권이 될 수 있다(대법원 2009.11.12. 선고 2009다53437 판결).

(3) 채무초과

채무초과 상태에 있는 위탁자가 부동산을 신탁한 경우에 다른 재산만으로는 채무를 변제할 수 없는 때 신탁을 설정한 경우이어야 한다.

처분행위 당시에는 채권자를 해하는 것이었다고 하더라도 그 후 채무자가 자력을 회복하여 사해행위취소권을 행사하는 사실심의 변론종결시에는 채권자를 해하지 않게 된 경우에는 책임재산 보전의 필요성이 없어지게 되어 채권자취소권이 소멸하는 것으로 보아야 할 것인바, 그러한 사정변경이 있다는 사실은 채권자취소소송의 상대방이 증명하여야 한다(대법원 2007.11.29. 선고 2007다54849 판결).

(4) 사해신탁에 대한 손해배상 책임

신탁이 취소되어 신탁재산이 원상회복된 경우 위탁자는 취소된 신탁과 관련하여 그 신탁의 수탁자와 거래한 선의의 제3자에 대하여 원상회복된 신탁재산의 한도 내에서 책임을 진다(신탁법 제8조제4항).

위탁자와 사해신탁(詐害信託)의 설정을 공모하거나 위탁자에게 사해신탁의 설정을 교사·방조한 수익자 또는 수탁자는 위탁자와 연대하여 이로 인하여 채권자가 받은 손해를 배상할 책임을 진다(신탁법 제8조제6항).

채권자는 악의의 수익자에게 그가 취득한 수익권을 위탁자에게 양도할 것을 청구할 수 있다. 이때 채권자취소권을 행사할 경우 채권자는 취소원인을 안 날부터 1년, 법률행위가 있는 날부터 5년 내에 제기해야 한다(신탁법 제8조제5항 및 민법 제406조제1항 준용).

여기에서 채권자가 ‘취소원인을 안 날’이라 함은 단순히 채무자가 재산의 처분행위를 하였다는 사실을 아는 것만으로는 부족하고, 그 법률행위가 채권자를 해하는 행위라는 것, 즉 그에 의하여 채권의 공동담보에 부족이 생기거나 이미 부

족상태에 있는 공동담보가 한층 더 부족하게 되어 채권을 완전하게 만족시킬 수 없게 되었으며 나아가 채무자에게 사해의 의사가 있었다는 사실까지 알 것을 요한다(대법원 2003. 12. 12. 선고 2003다40286 판결, 대법원 2006.11.9. 선고 2006다46483 판결).

사해행위에 해당하는 법률행위가 언제 있었는가는 실제로 그러한 사해행위가 이루어진 날을 표준으로 판정할 것이되, 이를 판정하기 곤란한 경우 등에는 처분 문서에 기초한 것으로 보이는 등기부상 등기원인일자를 중심으로 그러한 사해행위가 실제로 이루어졌는지 여부를 판정할 수 있다(대법원 2010.2.25. 선고 2007다28819,28826 판결).

소멸시효를 원용할 수 있는 사람은 권리의 소멸에 의하여 직접 이익을 받는 자에 한정되는데, 사해행위취소소송의 상대방이 된 사해행위의 수익자는, 사해행위가 취소되면 사해행위에 의하여 얻은 이익을 상실하고 사해행위취소권을 행사하는 채권자의 채권이 소멸하면 그와 같은 이익의 상실을 면하는 지위에 있으므로, 그 채권의 소멸에 의하여 직접 이익을 받는 자에 해당하는 것으로 보아야 한다(대법원 2007.11.29. 선고 2007다54849 판결).

[판례] 신탁법 제8조의 사해신탁의 취소에 민법 제406조 제2항의 제척기간의 규정도 적용되는지 여부

신탁법 제8조가 규정하고 있는 사해신탁의 취소도 민법상의 채권자취소권과 마찬가지로 책임재산의 보전을 위한 것이므로 피보전채권은 금전채권이어서 아니고, 특정물에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 행사하는 것은 허용되지 않는 점, 위 신탁법 규정에서도 '민법 제406조 제1항의 취소 및 원상회복 청구'라고 명시하고 있는 점 등에 비추어 보면, 신탁법에 규정된 사해신탁도 민법상의 사해행위와 그 본질적인 성격을 같이 한다 할 것이고, 또한 신탁법 제8조는 민법 제406조 제1항에 대한 특칙의 형태로 규정되어 있는바, 제척기간에 대하여 이러한 특칙의 규정이 없는 이상 오히려 민법의 제척기간에 관한 규정이 당연히 적용된다고 해석함이 상당하다(인천지법 2004. 11. 17. 선고 2003가합13044 판결).

(5) 사해신탁의 상대방

사해신탁의 상대방은 수탁자나 수익자이다. 따라서 수탁자와 수익자 모두를

피고로 하여 취소 및 원상회복을 구할 수 있다.

신탁의 법률관계는 회사와 같은 단체관계로 획일적 확정이 필요하고, 채권자의 재판청구권을 부당하게 제한하는 것은 부당하며, 수익자가 신탁재산으로부터 수익을 받는 경우에는 이에 대한 강제집행을 인정할 필요도 있으므로 개정 신탁법에서는 위탁자의 채권자로 하여금 수탁자와 수익자 모두를 피고로 하여 취소 및 원상회복을 구할 수 있도록 하였다.¹⁰⁷⁾

여러 명의 수익자 중 일부가 수익권을 취득할 당시 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 악의의 수익자만을 상대로 그 취소 및 원상회복을 청구할 수 있다(신탁법 제8조 제2항 단서). 그러나 수익자의 경우 수익권을 취득할 당시 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 그 취소 및 원상회복을 청구할 수 없다(신탁법 제8조 제1항 단서).

(6) 행사의 범위

사해행위로 원상회복을 청구할 수 있는 신탁재산의 범위는 선의의 수탁자에게 현존하는 신탁재산의 범위 내에서 원상회복을 청구할 수 있다(신탁법 제8조 제3항). 그러나 목적물이 불가분한 사실을 주장·입증한 경우에는 자신의 채권액을 넘어서 전체에 대하여 취소권을 행사할 수 있으며, 이 경우 목적물의 불가분성은 반드시 물리적·법률적인 것이 아니라 사회경제적 단일성과 거래의 실정을 고려하여 결정된다.¹⁰⁸⁾

채권자가 “채권자취소권을 행사할 때에는 원칙적으로 자신의 채권액을 초과하여 취소권을 행사할 수 없고(대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다63912 판결), 동일인의 소유인 토지와 건물의 처분행위를 채권자취소권에 의하여 취소하는 경우 그중 대지의 가격이 채권자의 채권액보다 다액이라 하더라도 대지와 건물 중 일방만을 취소하게 되면 건물의 소유자와 대지의 소유자가 다르게 되어 가격과 효용을 현저히 감소시킬 것이므로 전부를 취소함이 정당하다(대법원 1975.2.25. 선고 74다2114 판결).”고 한 판례가 있다.

107) 법무부 발행 신탁법 해설 78쪽

108) 법무부 발행 신탁법 해설 79쪽

채권자는 악의의 수익자에게 그가 취득한 수익권을 위탁자에게 양도할 것을 청구할 수 있다(신탁법 제8조 제5항).

위탁자와 사해신탁(詐害信託)의 설정을 공모하거나 위탁자에게 사해신탁의 설정을 교사·방조한 수익자 또는 수탁자는 위탁자와 연대하여 이로 인하여 채권자가 받은 손해를 배상할 책임을 진다(신탁법 제8조 제6항).

(7) 원상회복의 방법

민법상의 채권자취소권과 마찬가지로, 원상회복은 신탁재산 또는 그 대위물을 위탁자에게 반환하는 ‘원물반환’이 원칙이나, 거래관념상 원물반환이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 ‘가해반환’의 방법으로 하여야 한다. 특히 신탁을 설정한 이후에 수탁자의 자금투입으로 신탁재산의 가치가 증가한 경우에는 수탁자에게 신탁재산을 그대로 반환하는 것이 부당하고 원래의 가치만큼 가액 배상하도록 하여야 한다는 견해¹⁰⁹⁾가 있다.

원물반환이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우란 ㉠목적물이 멸실되거나 금전과 같이 일반재산에 혼입되어 특정성을 상실하는 경우와 같이 사실상 불가능한 경우 ㉡저당권부 부동산의 양도 후 저당권의 소멸로 인하여 공평의 관념에서 원상회복이 불가능한 경우(아래 판례 참조) 등을 들 수 있다.¹¹⁰⁾

가액배상은 ① 채권자의 피보전채권액 ② 사해신탁의 신탁재산인 목적물의 공동담보가액, ③ 수탁자·수익자가 취득한 이익 중 가장적은 금액을 한도로 이루어지며, 위 가액은 사실심 변론종결 시를 기준으로 하여 산정된다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001다33734 판결).

[판례] 채권자의 사해행위취소 및 원상회복청구가 인정되면, 수익자는 원상회복으로서 사해행위의 목적물을 채무자에게 반환할 의무를 지게 되고, 만일 원물반환이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 원상회복의무의 이행으로서 사해행위 목적물의 가액 상당을 배상하여야 하는바, 여기에서 원물반환이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우라 함은 원물반환이 단순히 절대적, 물리적으

109) 이중기 신탁법 80쪽

110) 이상경 주석 민법 채권총칙(2) (편집대표) 박준서). 109쪽

로 불능인 경우가 아니라 사회생활상의 경험법칙 또는 거래상의 관념에 비추어 그 이행의 실현을 기대할 수 없는 경우를 말하는 것이므로, 사해행위 후 그 목적물에 관하여 제3자가 저당권이나 지상권 등의 권리를 취득한 경우에는 수익자가 목적물을 저당권 등의 제한이 없는 상태로 회복하여 이전하여 줄 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권자는 수익자를 상대로 원물반환 대신 그 가액 상당의 배상을 구할 수도 있다고 할 것이나, 그렇다고 하여 채권자가 스스로 위험이나 불이익을 감수하면서 원물반환을 구하는 것까지 허용되지 아니하는 것으로 볼 것은 아니고, 그 경우 채권자는 원상회복 방법으로 가액배상 대신 수익자 명의의 등기의 말소를 구하거나 수익자를 상대로 채무자 앞으로 직접 소유권이전등기절차를 이행할 것을 구할 수 있다(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다57139 판결).

(8) 판결례

(가) 신탁행위가 사해행위에 해당하지 않는다고 한 사례

㉠ 채무자가 토지에 집합건물을 지어 분양하는 사업을 추진하던 중 이미 일부가 분양되었는데도 공정률 45.8%의 상태에서 자금난으로 공사를 계속할 수 없게 되자 건축을 계속 추진하여 건물을 완공하는 것이 이미 분양받은 채권자들을 포함하여 채권자들의 피해를 줄이고 자신도 채무변제력을 회복하는 최선의 방법이라고 생각하고, 사업을 계속하기 위한 방법으로 신탁업법상의 신탁회사와 사이에 신탁계약을 체결한 것으로 자금난으로 공사를 계속할 수 없었던 채무자로서는 최대한의 변제력을 확보하는 최선의 방법이었고 또한 공사를 완공하기 위한 부득이한 조치였다고 판단되므로 사해행위에 해당되지 않는다고 한 사례(대법원 2003. 12. 12. 선고 2001다57884 판결).

㉡ 신탁법에 의하여 부동산을 신탁한 갑이 그 부동산 수익권의 근질권자인 을에 대한 피담보채무의 변제에 갈음하여 을의 동의를 얻어 신탁계약을 해지하고 갑 명의로 소유권이전등기를 마침과 동시에 을에게 소유권이전등기를 경료하여 준 경우, 을은 우선변제권을 가지고 있었고, 그 부동산의 시가가 피담보채무에 현저히 미치지 못하여 그로써 갑의 총재산이 감소되었다고 볼 수 없으므로 사해행위가 성립하지 않는다고 한 사례(광주고법 2000. 7. 26. 선고 98나2531 판결).

㉔ 채무자가 상가건물을 신축하여 분양하는 사업을 추진하던 중 이미 상가건물의 일부가 분양된 상태에서 자금난으로 인해 공사를 중단할 위기에 처하자 위 상가건물의 신축공사를 계속 추진하여 건물을 완공하는 것이 이미 분양받은 채권자들의 피해를 줄이고 자신도 채무변제력을 회복하는 최선의 방법이라고 생각하고 사업을 계속하기 위한 방법으로 신탁회사와 신탁계약을 체결한 경우, 채무자로서는 신탁계약이 최대한의 변제력을 확보하는 최선의 방법이었으며, 또한 공사를 완공하기 위한 부득이한 조치였다고 할 것이어서 결국 위 신탁계약은 사해행위에 해당하지 않는다고 한 사례(인천지법 2004. 11. 17. 선고 2003가합13044 판결).

㉕ 공사대금을 지급받지 못한 아파트 공사 수급인이 신축 아파트에 대한 유치권을 포기하는 대신 수분양자들로부터 미납입 분양대금을 직접 지급받기로 하고, 그 담보를 위해 도급인과의 사이에 당해 아파트를 대상으로 수익자를 수급인으로 하는 신탁계약을 체결하고 수급인이 지정하는 자 앞으로 소유권이전등기를 경료하게 한 경우, 수급인의 지위가 유치권을 행사할 수 있는 지위보다 강화된 것이 아니고, 도급인의 일반채권자들 입장에서도 수급인이 유치권을 행사하여 도급인의 분양사업 수행이 불가능해지는 경우와 비교할 때 더 불리해지는 것은 아니므로 위 신탁계약이 사해행위에 해당하지 않는다고 한 사례(대법원 2001. 7. 27. 선고 2001다13709 판결).

㉖ 타인에 대하여 채무를 부담하는 사람이 자신이 소유한 재산 전부인 부동산에 관하여 제3자와 신탁계약을 체결하고 그에 따라 위 부동산을 수탁자인 제3자에게 신탁재산으로 이전하는 경우 위탁자에게는 그 채권자가 강제집행을 할 수 있는 책임재산이 더 이상 남아 있지 아니하므로 신탁법 제8조에서 정한 사해신탁에 해당할 수 있다. 그러나 자금난으로 사업을 계속 추진하기 어려운 상황에 처한 채무자가 자금을 융통하여 사업을 계속 추진하는 것이 채무변제력을 갖게 되는 최선의 방법이라고 생각하고 자금을 융통하기 위한 방편으로 신탁계약의 체결에 이르게 된 경우 이를 사해행위라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 신탁계약상 위탁자가 스스로 수익자가 되는 이른바 자익신탁의 경우 신탁재산은 위탁자의 책임재산에서 제외되지만 다른 한편으로 위탁자는 신탁계약에 따른 수익권

을 갖게 되어 위탁자의 채권자가 이에 대하여 강제집행을 할 수 있고, 이러한 수익권은 채무자가 유일한 재산인 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸는 등의 행위와 달리 일반채권자들의 강제집행을 피해 은밀한 방법으로 처분되기 어려우며, 특히 수탁자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 인가받아 신탁을 영업으로 하는 신탁업자인 경우 공신력 있는 신탁사무의 처리를 기대할 수 있으므로, 위탁자가 사업의 계속을 위하여 자익신탁을 설정한 것이 사해행위에 해당하는지 여부를 판단할 때는 단순히 신탁재산이 위탁자의 책임재산에서 이탈하여 외견상 무자력에 이르게 된다는 측면에만 주목할 것이 아니라, 신탁의 동기와 신탁계약의 내용, 이에 따른 위탁자의 지위, 신탁의 상대방 등을 두루 살펴 신탁의 설정으로 위탁자의 책임재산이나 변제능력에 실질적인 감소가 초래되었는지, 이에 따라 위탁자의 채무면탈이 가능해지거나 수탁자 등 제3자에게 부당한 이익이 귀속되는지, 채권자들의 실효적 강제집행이나 그밖의 채권 만족의 가능성에 새로운 장애가 생겨났는지 여부를 신중히 검토하여 판단하여야 한다(대법원 2011.5.23. 자 2009마1176 결정).

㉔ 매도인 갑이 매매목적물인 부동산을 을에게 신탁하고 이전등기를 마치자 매수인 병이 위 부동산 소유권이전등기의무의 이행불능에 따른 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 위 신탁이 사해행위에 해당한다고 주장한 사안에서, 신탁의 성질상 매도인 갑이 소유권에 관한 등기명의를 회복하여 병에게 이전등기해주는 것이 불가능하게 되었다고 단정할 수 없으므로 병이 갑에 대하여 손해배상청구권을 가진다고 단정할 수 없고, 갑의 행위가 사해행위에 해당한다고 단정할 수도 없다는 이유로 병의 사해행위취소청구를 인용한 원심을 파기한 사례(대법원 2010.4.29. 선고 2009다99129 판결).

(나) 신탁행위가 사해행위에 해당한다고 한 사례

채무자가 채무를 변제하지 아니한 채 그의 유일한 재산인 부동산에 관하여 제3자와 사이에 신탁계약을 체결하고 그 제3자 명의로 소유권이전등기를 경료한 경우, 그 신탁계약은 채권자를 해함을 알고서 한 사해행위라고 봄이 상당하다(대법원 1999. 9. 7. 선고 98다41490 판결).

5. 사해신탁에 대한 가처분

가. 보전의 필요성

계쟁물에 관한 가처분의 필요성은 계쟁물인 특정물의 현상에 변경이 생길 우려가 있어 미리 가처분을 하여두지 않으면 그 현상변경으로 청구권의 실현이 불가능하거나 현저히 곤란하게 되는 경우에 인정된다(민사집행법 제300조 1항). 그 사유가 채무자의 책임있는 사유인가 아닌가는 묻지 않는다. 권리실행의 태양에 따라 가처분의 방법도 다르므로 구체적으로는 가처분의 필요성이 가처분마다 특정되지 않으면 안된다. 물건인도의 보전이면 계쟁물의 현상유지 특히 점유상태의 고정과 물적 현상의 보전이 필요하고 그것을 이유있게 하는 사실로서는 채무자가 양도, 전세, 임대 등 점유를 이전할 우려가 있거나 건물을 헐거나 개축하는 등으로 계쟁물을 훼손, 손괴할 염려가 있는 것 등을 들 수 있고 등기청구권의 집행보전이면 계쟁물에 관한 권리관계 또는 그 표상의 현상에 대한 동결이 필요하고 그것을 이유있게 하기 위한 사실로서는 채무자가 양도 또는 저당권 전세권 설정 기타의 처분을 할 염려가 있는 것 등을 들고 있다.

나. 피보전권리

피보전권리는 원칙적으로 사해신탁행위 이전에 발생하고 있어야하나, 채권자 취소권과 같이 예외적으로 ① 사해신탁행위 당시에 이미 채권 성립의 기초가 되는 법률관계가 발생되어 있고, ② 가까운 장래에 그 법률관계에 터잡아 채권이 성립되리라는 점에 대한 고도의 개연성이 있으며, ③ 실제로 가까운 장래에 그 개연성이 현실화되어 채권이 성립된 경우에는 그 채권도 피보전채권이 될 수 있다(대법원 2009.11.12. 선고 2009다53437 판결).

다. 신청절차

(1) 개 설

가처분의 신청은 보전절차의 성질에 반하지 않는 한 소에 관한 규정이 준용된다. 가처분의 신청은 통상 본안소송을 제기하기 전에 신청하고 있으나 본안소송

의 계속 중에도 신청할 수 있다.

가처분의 신청은 피보전권리가 동일하다 하더라도 보전의 필요가 있고 또 보전처분의 내용이 서로 저촉되지 않는 범위내에서 수개의 보전처분을 구할 수 있다. 가처분신청은 주관적, 객관적으로 병합하여 신청할 수 있고, 신청 후 이를 변경할 수도 있다.

가처분의 신청은 시효의 중단 등 실체법상의 효과가 있다(민법 제168조 2호). 시효중단의 효력발생시기에 대하여는 견해에 대립이 있으나 보전처분의 신청을 한 때부터 발생한다고 본다.

(2) 첨부서면

㉠ 사해행위취소권에 근거하여 처분금지를 구하는 경우에는 채무자가 채무초과와 무자력이라는 점에 관한 구체적인 소명자료를 첨부하여야 한다. 무자력 내지는 사해의사에 관한 소명이 충분하지 아니한 경우에는 채무자의 관계를 소명하여 채권자가 사해행위취소권을 행사할 수 있는 요건이 갖추어졌음을 소명하여야 한다.

㉡ 채권이 이행기에 도래하기 전에 법률행위에 대하여 사해행위취소를 구하는 경우에는 법률행위 당시 이미 채권자에 대한 채권이 발생하였거나 또는 그렇지 않다면 그 당시 가까운 장래에 채권자에 대한 채권이 발생하리라는 점에 대한 고도의 개연성이 있었음을 소명하여야 한다.

(3) 등록면허세와 지방교육세 납부

가처분의 경우 등록면허세는 목적물가액이 있는 경우에는 그 가액으로, 목적물가액이 없는 경우에는 채권금액으로 정한 후 그 금액에 1,000분의2를, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20을 곱하여 산출한다. 즉, 건물인 경우는 “건물시가표준액표”에 의한 목적물가액이, 토지의 경우에는 개별공시지가확인원에 의한 공시지가금액이 표준이 된다.

등록면허세는 부동산가처분신청서를 작성하여 부동산소재지 시, 군, 구청의 세정과를 방문하여 등록면허세고지서를 발급받아 은행에 납부한다. 등록면허세

는 가처분신청시에 납부하거나 가처분신청 후 법원으로부터 가처분신청이 인용된 후 보증금공탁서와 함께 납부 할 수도 있다.

등록면허세 등은 가처분신청이 취하나 각하, 기각 또는 가처분집행이 미집행되거나 집행불능된 경우에는 법원으로부터 등록면허세영수필 확인서를 환부받아 등록면허세고지서를 발급한 시, 군, 구청에서 납부한 등록면허세를 환불을 받을 수 있다.

(4) 인지대와 송달료

10,000원의 인지를 법원 구내 우체국에서 구입하여 신청서 앞면에 부치고 당사자 1인당 3회에 해당하는 송달료(1회에 5,500원)를 법원구내 은행에서 송달료납부서를 작성하여 예납하고 그 납부서를 신청서 표지 뒷면에 풀로 붙인다.

(5) 담보의 제공

담보액의 산정은 법원이 자유재량에 의하여 정하나 일정한 기준에 의하는데 담보공탁금 산정기준은 청구금액의 1/10에 해당하는 금액을 현금공탁 또는 보증보험증권으로 제출토록 한다. 부동산을 가처분하려고 현금으로 공탁한다면, 법원에 100만 원을 공탁해야 가처분을 할 수 있다.

보증보험을 이용하면 보험료는 $1,000만\ 원 \times 1/10(10\%) \times 0.151\% = 1,510원$ 이다. 주의할 점은 보증보험료를 산출하여 15,000원 이하로 나오면 보증보험료는 15,000원이다(즉, 최저보험료는 15,000원이다).

보증보험증권에 의한 담보제공에 대하여 불허가 결정을 하고 현금공탁을 명한 경우, 가압류·가처분 신청을 각하·기각한 경우, 담보금액을 감액한 경우, 채권자가 가압류 신청을 취하한 경우에는 보험료의 전부 또는 일부의 환급이 가능하다. 환급받을 수 있는 금액은 보험료 전액이 아니라 최저보험료 15,000원을 뺀 금액만을 환급받을 수 있다.

(6) 부동산가처분등기 촉탁수수료

부동산·자동차·선박·항공기의 가처분은 법원이 집행처분의 명령과 동시

에 관련 행정관서에 등기·등록을 촉탁하여 집행하므로 증지를 첩부하여야 한다. 위 신청이 인용되면 법원은 위 말소등기청구권을 보전하기 위하여 수탁자 명의로 된 신탁부동산에 대하여 위 피보전권리의 가처분등기를 등기소에 촉탁함으로써 한다.

증지는 가처분결정 후 그 결정을 등기부에 기록하는 경우에 즉, 등기촉탁시 촉탁서에 첩부하는 경우에 필요한 것이므로 가처분결정을 채무자에게 송달하는 방법에 의하여 집행하는 경우에는 필요로 하지 아니한다.

물건 또는 권리의 양도, 담보권설정 기타의 처분을 금지하는 가처분의 집행은 가처분법원이 집행법원이 되어 등기공무원에게 등기부에 기입할 것을 촉탁함으로써 하고(민사집행법 제305조 3항, 제293조 동 규칙 제202조), 부작위를 명하는 등의 권리처분금지가처분은 그 결정을 채무자에게 송달하는 방법에 의한다.

증지의 경우 신청서에 폴로 붙이면 안되고 그대로 신청서와 함께 제출한다. 토지와 건물을 가처분하는 경우에는 증지대는 8,000원이나 아파트와 연립의 경우에는 4,000원이다(등기부 등·초본 등 수수료규칙 제5조의2②). 전자표준에 의하여 신청하는 경우의 신청수수료는 매 부동산마다 3,000원으로 한다(등기부 등·초본 등 수수료규칙 제5조의5②).

라. 가처분에 의한 처분금지의 효력

목적물에 대한 처분금지가처분결정이 내려진 경우 가처분에 의한 처분금지의 효력은 가처분채권자의 권리를 침해하는 한도에서만 생기는 것이므로, 가처분채권자는 피보전권리의 한도에서 가처분 위반의 처분행위의 효력을 부정할 수 있다 할 것인바(대법원 1984. 4. 16.자 84마7 결정, 1988. 4. 25. 선고 87다카458 판결, 1991. 4. 12. 선고 90다9407 판결 등), 채권자취소권은 사해행위로 이루어진 채무자의 재산처분행위를 취소하고 그 원상회복을 구하기 위한 권리로서 사해행위에 의해 일탈된 채무자의 책임재산을 총채권자를 위하여 채무자에게 복귀시키기 위한 것이지 채권자취소권을 행사하는 특정 채권자에게만 독점적 만족을 주기 위한 권리가 아니다(대법원 2006.8.24. 선고 2004다23110 판결).

피보전권리를 사해신탁을 원인으로 한 소유권이전등기말소청구권 등으로 하여 신탁부동산에 대하여 처분금지가처분등기가 경료된 경우, 신탁의 해지로 신탁등기의 말소와 함께 신탁재산을 귀속권리자에게 이전함에 있어서의 권리귀속은 일반절차에 따라 소유권이전등기의 형식으로 이루어진다. 그러므로 가처분의 목적이 된 수탁자명의로의 소유권이전등기 및 가처분등기가 말소되는 것은 아니다(2005. 11. 2. 부동산등기과-1870 질의회답).

[서식] 부동산 처분금지 가처분신청(사해행위취소권에 기한 소유권이전 등기의 말소등기청구권)

부동산 처분금지 가처분 신청서

신청인(채권자) ○○인테리어(주)(000000 - 000000)

서울시 서초구 서초로 601 - 4 우편번호 00000

대표이사 임 중 수

(전화 000-000-0000, 근무처 02)000-0000)

피신청인(채무자) 서울○○신탁 주식회사(000000-000000)

서울시 서초구 서초로 144-25 우편번호 00000

대표이사 김 갑 수

(전화 000-000-0000, 근무처 02)000-0000)

목적물의 표시

별지목록과 같음

목적물의 가격

금00,000,000원

피보전권리

사해행위취소에 기한 신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기 말소청구
권

신 청 취 지

피신청인은 별지목록 기재 부동산에 관하여 매매, 양도, 저당권, 임차
권의 설정 기타 일체의 처분을 하여서는 아니된다.

라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

1. 원인관계

가. 소외 김철수는 서울시 서초구 서초중앙로 100-20의 주소지의 ○○상가(이하 “상가”라 한다)의 소유권자이고, 신청인은 위 김철수로부터 위 상가의 내부인테리어 공사와 그 주변의 조경공사(이하 “인테리어 공사 등”이라 한다)를 한 회사이고, 피신청인은 위 김철수와 “유언대용신탁 계약”을 체결하고 위 상가의 소유권을 김철수로부터 이전 받아 관리하는 신탁회사입니다.

나. 위 김철수는 위 상가의 내부인테리어 등 공사를 신청인과 20○○. 10. 18 공사금액 일금000,000원에 계약을 체결한 후 신청인은 20○○. 9. 경 위 상가의 공사를 완공하였는데 위 김철수는 소유권보존과 동시에 위 상가를 20○○. 9. 20 피신청인에게 신탁해 놓았습니다.

2. 사해행위

가. 위 김철수는 위 상가를 담보로 준공과 동시에 서초동의 현대상호신용금고에서 5억 8천만원, ○○상호저축은행에서 6억 5천만원, 우리은행에서 6억원 등 총 130억원을 대출 받았으며 사채로는 약15억원(위 금액은 등기부등본 상에 나타나 있는 금액임)이 있으며 미지급한 하도급공사대금은 15개 하도급업체에 약30억원(위 김철수를 상대로 한 공사대금판결금액임)에 이릅니다.

나. 위 신탁은 “유언대용신탁”으로써 동 신탁원부 제1조 “신탁의 목적”은 “이 신탁계약은 수탁자가 신탁부동산의 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산에서 수익금을 지급받아 노후설계 자금으로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 이 신탁재산을

상속받을 자를 위하여 그 사무처리를 함을 목적으로 한다.”로 되어있는 바, 위 신탁목적은 보더라도 상가분양을 목적으로 한 신탁이 아니고 채권을 피하기 위한 사해행위임을 알 수 있습니다.

- 다. 이와 같이 위 김철수는 채무초과로 인한 지급불능 및 지급정지 상태에 있음을 알 수 있고 이로 인한 위 “유언대용신탁”은 마땅히 취소되어야 합니다.

3. 판례 및 선례

채무자가 채무를 변제하지 아니한 채 그의 유일한 재산인 부동산에 관하여 제3자와 사이에 신탁계약을 체결하고 그 제3자 명의로 소유권이전 등기를 경료한 경우, 그 신탁계약은 채권자를 해함을 알고서 한 사해행위라고 봄이 상당하다는 판례(대법원 1999. 9. 7. 선고 98다41490 판결)가 있습니다.

4. 결론

- 가. 신청인은 위 김철수를 상대로 공사잔대금청구소송을 준비중에 있으므로 위 김철수 앞으로의 재산이라고는 그나마 금융권으로부터 대출을 하고 피신청인에게 신탁해 놓은 별지목록기재의 상가일 뿐이므로 이를 보전하기 위하여 본 가처분에 이르렀습니다.
- 나. 본건 가처분의 손해담보로 제공할 공탁금은 민사집행법 제19조 제3항, 민사소송법 제122조에 의하여 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법에 의하여 담보를 제공할 것을 허가하여 주시기 바랍니다.

소 명 방 법

- | | |
|-------------|----|
| 1. 신탁원부 | 1통 |
| 1. 공사계약서 사본 | 1통 |

첨 부 서 류

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 법인등기부등본(서울○○신탁 주식회사) | 1통 |
| 1. 법인등기부등본(신청인) | 1통 |
| 1. 부동산등기부등본 | 1통 |
| 1. 위 소명서류 전부 | |

20 . 9. .

위 신청인 ○○인테리어(주) (인)

서울중앙지방법원 귀중

6. 사해신탁을 원인으로 한 신탁해지등기(확정판결에 의한)

가. 개 설

채무자의 부동산 신탁행위가 사해행위에 해당하면 채권자는 신탁회사를 상대로 사해신탁을 원인으로 한 소유권이전등기말소청구권의 이행을 명하는 확정판결을 받아 채무자를 대위하여 신탁재산을 신탁행위 전의 상태로 채무자에게로 원상회복 한 후 채권을 회수하여야 한다.

[판례] 신탁한 부동산을 매도한 행위가 사해행위에 해당하는 경우 그 처리절차 채무자의 부동산 매도행위가 사해행위에 해당하면 채권자는 채권자취소권을 행사하여 그 매매계약을 취소하고 소유권이전등기의 말소 등 부동산 소유권 자체의 회복을 구할 수 있는 것이 원칙이지만, 채무자가 제3자에 대한 채무 담보의 목적으로 신탁법에 의하여 신탁한 부동산을 매도한 행위가 사해행위에 해당하는 경우, 매수인이 채무자를 대위하여 제3자에 대한 채무를 변제하고 신탁계약을 해지하여 그 부동산의 소유권을 이전받았다면, 그 매매계약을 취소하여 신탁계약이 해지되기 전의 상태로 원상회복하는 것은 현저히 곤란하고, 그렇다고 부동산의 소유권 자체를 채무자에게 환원시키는 것은 당초 일반 채권자들의 공동담보로 되어 있지 아니한 부분까지 회복시키는 결과가 되어 공평에 반하므로, 결국 채권자는 부동산의 가액에서 매수인이 대위변제한 채무액을 공제한 잔액의 한도 내에서 매매계약의 일부 취소와 그 가액의 배상을 청구할 수밖에 없다고 보아야 하고, 매수인 앞으로 소유권이전등기가 마쳐지기 전에 채무자 앞으로 신탁재산의 귀속을 원인으로 한 소유권이전등기가 마쳐지는 중간과정을 거쳤다 하여 달리 볼 것은 아니다(대법원 1999. 11. 9. 선고 99다50101 판결).

나. 신탁해지등기절차

(1) 개 설

확정판결을 받은 자는 채무자를 대위하여 소유권이전등기와 신탁등기의 말소를 동일한 신청서에 의하여 신청하여야 한다.

신탁재산에 속한 권리가 이전 또는 소멸됨에 따라 신탁재산에 속하지 아니하게 된 경우 신탁등기의 말소신청은 신탁된 권리의 이전등기 또는 말소등기의 신

청과 동시에 하여야 한다(부동산등기법 제87조 제2항, 등기예규 제1799호).

등기권리자는 신탁해지에 의한 신탁재산의 귀속자가 되고, 등기의무자는 등기명의인인 수탁자가 된다.

(2) 등기원인과 그 연월일

사해행위취소판결의 주문에 원상회복의 방법으로 소유권이전등기의 말소등기절차의 이행을 명하는 대신 소유권이전등기절차의 이행을 명하면서 그 등기원인을 “사해행위취소” 외에 “사해행위취소로 인한 원상회복” 또는 “진정명의회복” 등으로 기재하였더라도 어느 경우에도 사해행위취소판결 자체가 그 등기의 원인이 되는 것은 마찬가지이므로, 이러한 판결에 의하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에 신청정보의 내용 중 등기원인은 “사해행위취소”로, 그 연월일은 “판결확정일”로 하여 이를 제공하여야 한다(부동산등기선례 제201809-7호, 2018. 09. 20. 부동산등기과-2136 질의회답).

확정판결에 의한 등기절차에 관한 구체적 내용은 595면 참조

다. 첨부서류

1) 사해신탁을 원인으로 한 소유권이전등기말소청구권의 이행을 명하는 확정판결정본과 확정판결증명원을 첨부하여야 한다.

2) 소유권이전 및 신탁말소등기 신청 시 말소의 대상이 되는 신탁등기 신청정보 : 신탁재산 귀속을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때에는 말소할 사항으로서 말소의 대상인 신탁등기를 특정하여 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 하는바, 다만 이전등기의 대상인 소유권등기와 말소등기의 대상인 신탁등기가 같은 순위번호를 사용하고 있는 경우에는 신청정보의 내용 중 “말소할 사항”에 관하여는 그 제공을 생략할 수 있다(부동산등기선례 제201906-1호, 2019. 6. 3. 부동산등기과-1331 질의회답).

3) 신탁부동산에 대하여 피보전권리를 사해신탁을 원인으로 한 소유권이전등기말소청구권 등으로 하여 처분금지가처분등기가 경료된 경우, 신탁의 해지로 신탁등기의 말소와 함께 신탁재산을 귀속권리자에게 이전함에 있어서는 가처분

권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본은 필요하지 않다(2005. 11. 2. 부동산등기과-1870 질의회답).

4) 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(집행권원)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).

라. 취득세 · 등록면허세 · 수수료 등

(1) 취득세

사해신탁을 원인으로 한 신탁해지등기는 신탁재산을 신탁행위 전의 상태로 채무자에게로 원상회복하여야 하므로 귀속권리자가 위탁자이다. 따라서 취득세를 부과하지 아니한다.

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 등록면허세 : 신탁종료로 인한 권리귀속을 원인으로 위탁자에게 소유권을 이전하는 경우에는 등록면허세는 면제된다(등기선례 200410-1, 2004. 10. 4. 부등 3402-496 질의회답). 그러나 위탁자가 아닌 수익자에게 이전하는 경우에는 부동산가액의 1천분의 20에 해당하는 등록면허세를 납부하여야 한다.

(나) 신탁말소등기의 등록면허세 : 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁말소의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁말소등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의 20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.

(3) 국민주택채권

신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니하나(주택기금법시행령 제95조 제1항 관련 별표12의 부표19호 가. 등기선례5-895), 수익자 및 제3자에게 소유권이

전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하여야 한다.

(4) 인지세

신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 귀속권리자와 상관없이 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(5) 등기신청 수수료

(가) 소유권이전등기

신탁종료로 인하여 신탁재산을 위탁자명의로 귀속시키는 경우 소유권이전등기의 신청수수료를 납부하여야 한다(아래 참조).

(나) 신탁등기의 말소

신탁등기의 말소등기 신청수수료는 아래와 같다.

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행 수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

라) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

바) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시

행 2025.08.05).

사) 방문신청의 경우 수수료 납부 : 부동산등기 신청수수료의 납부는 그 수수료 상당의 등기수입증지를 등기신청서에 붙여 제출하였으나 2013. 5.1부터 그 수수료 상당액을 법원행정처장이 지정하는 금융기관에 현금으로 납부한 후 이를 증명하는 서면을 등기신청서에 첨부하여 제출하는 방법으로 한다. 여러 건의 등기신청수수료를 현금으로 일괄 납부하는 경우 첫 번째 등기신청서에 영수필 확인서 등을 첨부하고 해당 등기신청수수료와 일괄납부 건수 및 일괄납부액을 기재하며, 나머지 신청서에는 해당 등기신청수수료와 전 사건에 일괄 납부한 취지를 기재한다(등기예규 제1576호).

아) 등기신청이 취하된 경우에는 납부된 등기신청수수료를 신청인 또는 그 대리인에게 반환한다.

[서식] 소유권이전등기 및 신탁등기말소(확정판결, 사해신탁을 원인으로 한 신탁해지)

소유권이전등기 및 신탁등기말소등기				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 16965.3㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 사해행위취소 확정판결		
등 기 의 목 적		신탁해지로 소유권이전 및 신탁등기전부말소		
신탁등기말소의 원인		신탁재산의 귀속		
말 소 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
대위 신청인	김갑수	000000 -000000	서울 서초구 서초동 223-66	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표 15호 가.)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 7,200원
등 기 신 청 수 수 료		금15,000원(이품의 경우)
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁원부	1통	1. 인감증명서(전자본인서명등) 1통
1. 토지대장	1통	1. 취득세(등록세)영수필확인 1통
1. 판결정본	1통	1. 위 임 장 1통
1. 판결확정증명원	1통	1. 주민등록등본 1통
1. 법인등기부등본	1통	
2000년 0월 0일		
위 신청인 ① (전 화:)		
(또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ① (전 화:)		
서울 서초구 서초동 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명) 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 사해신탁을 원인으로 한 신탁종료(해지)의 판결을 받아 대위에 의하여 소유권이전 및 신탁등기말소를 하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “사해신탁의 확정판결”로, 연월일은 확정판결일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁해지로 인한 소유권이전등기와 신탁등기말소를 동일신청서로 신청하므로 “신탁해지로 소유권이전 및 신탁등기전부말소”로 기재한다.
- 등기의무자란 : 대위신청인 단독으로 신청함으로 등기의무자를 생략한다.
- 등기권리자란 : 대위신청인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야

한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기원인을 증명하는 정보로서 당해 부동산에 관하여 사해행위취소로 인한 판결정본과 판결확정증명원을 첨부한다. 위 판결확정증명원은 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세·등록면허세·등기신청 수수료 등

- 597면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장		
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 16965.3㎡ 이 상	
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 사해신탁의 확정판결	
등 기 의 목 적	신탁해지로 소유권이전 및 신탁등기전부말소	
신탁등기말소의 원인	신탁재산의 귀속	
말 소 할 사 항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제 5634호)	
대위신청인 김갑수 ㉠ 서울 서초구 서초동 223-66	법무사 정 인 구 서울 서초구 서초동 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일	

주)법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

부 록